

2.

O ÁGIO E A MAIS-VALIA DE ATIVOS NA LEI Nº 12.973/2014

2.1. Introdução

No regime jurídico da Lei nº 12.973/2014, o contribuinte que avaliar investimento de acordo com o MEP deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:

(i) valor de patrimônio líquido na época da aquisição, apurado segundo o procedimento estabelecido na legislação em vigor;

(ii) mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da participação societária adquirida, e o valor de que trata o item (i) supra; e

(iii) ágio por rentabilidade futura (*goodwill*) ou ganho proveniente de compra vantajosa, que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os itens (i) e (ii) supra.

Como se vê, após a edição da Lei nº 12.973/2014, a mensuração e a alocação do ágio por rentabilidade futura passou a seguir a sistemática do Pronunciamento Técnico CPC nº 15 (“Combinação de Negócios”), por meio do qual a sociedade investidora deve realizar a alocação do preço de aquisição (“*purchase price allocation*”) ao valor justo¹ dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos. Consequentemente, apenas o valor residual poderá ser tratado como ágio por rentabilidade futura.

Em termos gráficos, a alocação do preço de aquisição sob a égide da Lei nº 12.973/2014 pode ser assim representada:

1. De acordo com as normas contábeis, o valor justo corresponde ao “preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração” (Vide item 9 do Pronunciamento Técnico CPC nº 46).

Valor da
contraprestação

Ágio (goodwill)
Mais-valia
Valor do patromônio líquido

Note-se que o § 5º, I e II, do artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977, incluído pela Lei nº 12.973/2014, passou a prever expressamente que o contribuinte deve, primeiramente, reconhecer e mensurar a valor justo os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos, para, somente então, reconhecer o ágio de rentabilidade futura ou o ganho proveniente de compra vantajosa. Trata-se, assim, de alocação do preço de aquisição que segue a sistemática prevista no item 32 do Pronunciamento Técnico CPC nº 15.

É importante registrar que essa ordem de alocação é uma notável inovação trazida pela Lei nº 12.973/2014, tendo em vista que, no regime anterior, o critério central para a alocação do ágio era o motivo ou fundamento que determinou o pagamento do sobrepreço². Assim, o ágio podia ser integralmente atribuído à perspectiva de rentabilidade futura da sociedade na hipótese em que o foco do adquirente estava nos resultados futuros do empreendimento. Em tais casos, o pagamento do ágio se justificava na expectativa de lucros que a utilização conjunta dos ativos proporcionava para a sociedade adquirida, mediante o aproveitamento dos benefícios da sinergia para o exercício de sua atividade econômica. Em outras palavras, o pagamento do ágio permitia a aquisição do conjunto organizado de fatores de produção da sociedade, que seria utilizado para a obtenção de resultados futuros.

2.2. O conceito de combinação de negócios

Segundo o Pronunciamento Técnico CPC nº 15, o conceito de combinação de negócios abrange a “operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação” (Apêndice A – Glossário).

Assim, o âmbito de aplicação do Pronunciamento Técnico CPC nº 15 alcança quaisquer operações que impliquem a transferência do controle de um negócio,

2. BIANCO, João Francisco; FAJERSZTAJN, Bruno. “Determinação e Fundamentação Econômica do Ágio Apurado na Aquisição de Investimentos: Regimes Fiscal e Contábil”. In: *Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A: Desafios da Neutralidade Tributária e do Direito Societário*. Volume III. Coord. Sergio André Rocha. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp. 347-348.

assim entendido o conjunto integrado de ativos capaz de ser conduzido e gerenciado para a obtenção de benefícios econômicos futuros, sob a forma de dividendos, redução de custos e outros proventos similares, para investidores, proprietários, membros ou participantes.

Note-se que, como o Pronunciamento Técnico CPC nº 15 apenas se aplica quando há a transferência do controle do negócio, as regras contábeis em questão não preveem o registro de ágio na aquisição de participação societária em sociedades coligadas ou em sociedades controladas em conjunto. Porém, para suprir a lacuna, a Interpretação Técnica ICPC nº 09 dispôs que a sociedade que adquirir participação societária em sociedade coligada ou controlada em conjunto deve utilizar a metodologia do Pronunciamento Técnico CPC nº 15, identificando os ativos e passivos transferidos a valor justo e reconhecendo apenas a diferença como ágio de rentabilidade futura ou como ganho por compra vantajosa, conforme o caso³. É o que preveem os itens 35 a 37 da Interpretação Técnica ICPC nº 09, abaixo transcritos:

“35. No caso de investimento em coligada ou em empreendimento controlado em conjunto, também os ativos líquidos identificáveis da investida (incluindo o passivo ou ativo fiscal diferido correspondente) na data da obtenção da influência significativa (ou do controle conjunto) devem ser mensurados a valor justo, bem como devem previamente ser ajustadas as demonstrações da investida às práticas contábeis da investidora, como mencionado nos itens 19 e 20.

36. Um investimento em empreendimento controlado em conjunto ou em coligada deve ser contabilizado na demonstração individual da investidora, usando-se o método da equivalência patrimonial a partir da data em que esta se torne empreendimento controlado em conjunto ou coligada. Na aquisição do investimento, qualquer diferença entre o custo do investimento (montante dado em troca da participação comprada e mais o valor justo de participação pré-existente na investida, se houver) e a parte do investidor no valor justo líquido dos ativos e dos passivos identificáveis do empreendimento controlado em conjunto ou coligada (já líquido do passivo fiscal diferido ou acrescido do ativo fiscal diferido) deve ser contabilizada da mesma forma como descrito nesta Interpretação para investimento em controlada, exceto pelo que consta do item 37.

No caso de aplicação da equivalência patrimonial em coligadas ou em empreendimentos controlados em conjunto, o ágio por expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*) deve estar contido no saldo contábil do investimento

3. HADDAD, Gustavo Lian; PAES, Gustavo Duarte. “O Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura na Lei 12.973 e o Goodwill na Combinação de Negócios – Aproximações e Distanciamentos”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 6º Volume. Coord. Roberto Quiroga Mosquera e Alexsandro Broedel Lopes. São Paulo: Dialética, 2015, p. 255.

a ser apresentado no balanço da entidade investidora, registrado dentro do subgrupo investimento no ativo não circulante, não podendo ser apresentado em separado no subgrupo dos ativos intangíveis.”

Por outro lado, o artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977, mesmo após a edição da Lei nº 12.973/2014, ainda determina o desdobramento do custo de aquisição em qualquer aquisição de participação societária avaliada pelo MEP, o que torna o âmbito de aplicação do regime tributário do ágio de rentabilidade futura distinto da sistemática geral do ágio reconhecido em operações de combinação de negócios. Veja-se:

“Art. 20. O contribuinte que avaliar *investimento pelo valor de patrimônio líquido* deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:

I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e

II – mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do *caput*; e

III – ágio por rentabilidade futura (*goodwill*), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do *caput*.”

Segundo o artigo 248 da Lei nº 6.404/1976, os seguintes investimentos são avaliados pelo MEP:

“Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em *coligadas* ou em *controladas* e em *outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo* ou *estejam sob controle comum* serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (...)” (g.n.)

Diversamente, o Pronunciamento Técnico CPC nº 18 prevê que o MEP deve ser aplicado por todas as entidades que sejam investidoras com o controle individual ou conjunto sobre outra entidade investida ou com influência significativa sobre ela (item 2). Veja-se: “Este Pronunciamento deve ser aplicado por todas as *entidades* que sejam investidoras com o controle individual ou conjunto de investida ou com influência significativa sobre ela” (g.n.).

A influência significativa é definida pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 18 como “o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas” (item 3).

Em geral, o termo “entidade” possui acepção ampla, que não se restringe ao conceito de sociedade ou de pessoa jurídica⁴. Assim, o conceito de entidade poderia, em tese, alcançar entes destituídos de personalidade jurídica.

Na doutrina contábil, Eliseu Martins e Sérgio de Iudícibus apontam que o conceito de entidade não está definido nas regras contábeis, pois o IASB ainda não emitiu um pronunciamento específico sobre o tema. Por isso, esses autores afirmam que o conceito de entidade apresenta muitas variações entre os países, sendo compreendido nos Estados Unidos como um grupo econômico de empresas, pois as regras contábeis locais (US GAAP), assim como aquelas baseadas no padrão IFRS, focam na apresentação do balanço consolidado⁵.

A falta de definição em relação ao conceito de entidade traz insegurança jurídica, pois o Fisco poderia alegar que, no Brasil, apenas as sociedades com personalidade jurídica possuem autonomia patrimonial para serem qualificadas como entidades, ou, ainda, que o conceito de entidade deve ser compreendido no contexto dos balanços consolidados, para limitar o aproveitamento do ágio em certas operações.

Além das potenciais divergências relacionadas aos investimentos avaliados pelo MEP, Raquel Novais e Bruna Marrara Martinez apontam que o âmbito de aplicação do artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 é mais amplo do que o regime de combinação de negócios, tendo em vista que o MEP é aplicável na aquisição de investimentos em sociedades coligadas, ao passo que o regime contábil do Pronunciamento Técnico CPC nº 15 pressupõe a aquisição do controle de um negócio.

4. Segundo De Plácido e Silva, na terminologia jurídica, o termo entidade “serve para distinguir e designar não somente os entes humanos (pessoa física), como qualquer instituição ou organização, cuja existência é considerada ou encarada indistinta e independentemente das próprias coisas ou pessoas físicas, mesmo que não se mostrem propriamente uma pessoa jurídica. Entidade, pois, no sentido jurídico, possui acepção mais ampla que pessoa jurídica (...)” (SILVA, De Plácido e. *Vocabulário Jurídico*. 18ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 309).

5. Veja-se: “(...) O IASB ainda não emitiu até hoje a definição de entidade. Ela sequer está no seu glossário. Usa essa palavra em praticamente todos os seus documentos (IASs, IFRSs, IFRICs etc.), mas não a define! Um caso extremo de conceituação do que seja entidade é o dos EUA. Lá, as normas contábeis só existem para o balanço consolidado quando da existência de uma entidade que controle pelo menos outra entidade. (...) Nos EUA, o conceito de entidade para fins contábeis é o da entidade econômica, do grupo econômico de empresas, e não o da entidade jurídica como estamos acostumados no Brasil. (...) No caso do IASB, ocorre, até um certo ponto, exatamente o mesmo: até hoje as suas normas dizem respeito basicamente às demonstrações consolidadas (individuais, igualmente à situação dos norte-americanos, só para entidade sem controlada (...))” (MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. “Ágio Interno – É um mito?”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 4º Volume. Coord. Roberto Quiroga Mosquera e Alessandro Broedel Lopes. São Paulo: Dialética, 2013, pp. 90-92).

Além disso, no âmbito do artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977, qualquer aquisição de participação societária relevante enseja o desdobramento do custo de aquisição, independentemente da aquisição de controle e de sua qualificação como uma operação de combinação de negócio⁶.

Entretanto, não há, necessariamente, maior amplitude da lei tributária. De um lado, a lei tributária permite o desdobramento do ágio em qualquer aquisição de participação societária avaliada pelo MEP, sendo que, em relação às sociedades coligadas e às sociedades sujeitas a controle comum, a limitação da regra contábil foi resolvida pela Interpretação Técnica ICPC nº 09, como examinado supra.

De outro lado, o Pronunciamento Técnico CPC nº 15 exige a transferência de controle de um negócio, mas adota uma definição ampla para o termo “negócio”, que não se vincula a qualquer forma jurídica específica, podendo alcançar a alienação de um estabelecimento, de uma unidade operacional ou de ativos líquidos, sem a necessidade de aquisição da pessoa jurídica detentora dos respectivos ativos. Assim, a verdade é que os âmbitos de aplicação do Decreto-lei nº 1.598/1977 e do Pronunciamento Técnico CPC nº 15 são distintos, não sendo necessário falar em maior ou menor abrangência.

Isso porque, enquanto o Pronunciamento Técnico CPC nº 15 permite o reconhecimento do ágio na aquisição do controle de qualquer negócio, o artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 alcança a aquisição de qualquer participação societária avaliada pelo MEP, independentemente da aquisição de controle. Assim, a contabilidade é mais ampla em relação ao conceito de negócio, mas mais restrita ao exigir a aquisição de controle, ao passo que o direito tributário é mais restrito ao demandar a aquisição de participação societária, mas não exige a configuração do poder de controle.

Veja-se, ainda, que a Interpretação Técnica ICPC nº 09 alcançou as sociedades coligadas e as sociedades sujeitas a controle comum, mas deixou de mencionar as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. Diversamente, o artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977, ao fazer alusão a qualquer investimento avaliada pelo MEP, absorvendo o conceito do artigo 248 da lei nº 6.404/1976, alcança as

6. Nas palavras de Raquel Novais e Bruna Marrara Martinez: “(...) a lei dá amplitude significativamente maior aos casos em que há reconhecimento de ágio quando comparada ao CPC 15. Isso porque, como mencionado acima, uma combinação de negócios pressupõe a aquisição de controle, enquanto o método da equivalência patrimonial para avaliação de investimento é aplicável também à aquisição de coligadas. Além disso, o evento que enseja o desdobramento do ágio nos termos da Lei 12.973/2014 é a aquisição de participação societária, independentemente de sua qualificação ou não como uma combinação de negócios” (NOVAIS, Raquel; MARTINEZ, Bruna Marrara. “A Lei 12.973/2014, a Empresa-veículo e Outros Temas”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 6º Volume. Coord. Roberto Quiroga Mosquera e Alexsandro Broedel Lopes. São Paulo: Dialética, 2015, p. 504).

sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, possuindo maior amplitude neste particular.

Diante disso, tem-se que:

(i) a contabilidade pode reconhecer o ágio em qualquer aquisição de negócio (v.g. aquisição de ativos), mas exige, como regra geral, a caracterização de controle, salvo em relação às coligadas;

(ii) o direito tributário alcança qualquer aquisição de participação societária avaliada pelo MEP, sem exigir a modificação do controle societário;

(iii) a contabilidade não menciona as demais sociedades integrantes do mesmo grupo econômico;

(iv) o direito tributário engloba as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, ainda que não sejam coligadas.

Em suma, o que se extrai da breve discussão supra é que o legislador tributário, ao editar a Lei nº 12.973/2014, se inspirou nas novas regras contábeis, mas manteve a independência do tratamento fiscal do ágio, que não está integralmente vinculado ao Pronunciamento Técnico CPC nº 15⁷.

Por conta de tal diferença no âmbito de aplicação das regras contábeis e fiscais a respeito do tema, é de se reconhecer que a lei tributária manteve o estímulo para que os contribuintes continuem transformando uma simples compra de ativos líquidos na aquisição de uma participação societária, apenas para fins de aproveitamento do ágio de rentabilidade futura. Isso porque o ágio decorrente de uma combinação de negócios, que não tomou a forma de aquisição de participação societária, não se submete ao regime tributário do artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 e do artigo 22 da Lei nº 12.973/2014⁸.

De fato, a Lei nº 12.973/2014 mantém o incentivo para que o contribuinte transforme a aquisição de um negócio na aquisição de uma participação societária, pois o ágio oriundo da compra de uma unidade de negócios (“*asset deal*”) não é dedutível para fins fiscais. Veja-se: “Art. 28. A contrapartida da redução do ágio por rentabilidade futura (*goodwill*), inclusive mediante redução ao valor recuperável, não será computada na determinação do lucro real. (...)”

A disfuncionalidade da Lei nº 12.973/2014, gerada pela assimetria de tratamento tributário, aumenta ainda mais em razão do ganho por compra vantajosa

7. LUZ, Victor Lyra Guimarães. *Fusões e Aquisições: Regime Jurídico do Ágio*. São Paulo: Almedina, 2019, p. 109; HADDAD, Gustavo Lian; PAES, Gustavo Duarte. “O Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura na Lei 12.973 e o Goodwill na Combinação de Negócios – Aproximações e Distanciamentos”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 6º Volume. Coord. Roberto Quiroga Mosquera e Alexsandro Broedel Lopes. São Paulo: Dialética, 2015, p. 269.

8. Sobre o tema, conferir: MUNIZ, Ian; MONTEIRO, Marco. *Tributos Federais e o Novo Padrão Contábil – Comentários à Lei nº 12.973/14*. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 153.

oriundo da aquisição de uma unidade de negócio (“*asset deal*”) ser submetido à incidência do IRPJ e a CSLL à razão de 1/60 para cada mês do período de apuração. Confira-se:

“Art. 27. O ganho decorrente do excesso do valor líquido dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos, mensurados pelos respectivos valores justos, em relação à contraprestação transferida, será computado na determinação do lucro real no período de apuração relativo à data do evento e posteriores, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração” (...).

Vale mencionar que, de acordo com as novas regras contábeis, o ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura não deve ser reconhecido como um ativo na contabilidade da sociedade adquirente, no caso de operação realizada dentro do mesmo grupo societário⁹.

Nesse sentido, o Pronunciamento Técnico CPC nº 15, ao tratar dos critérios de avaliação de ativos e passivos assumidos em operações de combinação de negócios, estabelece a sua inaplicabilidade às operações societárias realizadas entre partes relacionadas, integrantes do mesmo grupo econômico, em virtude da falta de independência entre as partes envolvidas. Assim, para a aplicação do conceito de combinação de negócios, exige-se a alteração de controle do empreendimento, por meio de ato ou negócio jurídico realizado entre partes independentes.

O ágio gerado entre pessoas jurídicas de um mesmo grupo econômico é questionável sob o ponto de vista contábil, em razão da suposta inexistência de valoração econômica. Isso porque a ciência contábil parte do pressuposto de que o ágio corresponde ao resultado econômico oriundo da aquisição de determinado empreendimento, por meio de um processo de negociação realizado entre partes independentes. Daí a ideia de que o ágio decorre de um processo de barganha negocial não viciado, que concorre para a formação de um preço justo. Por isso, o registro de ágio somente seria concebível em operações realizadas entre partes independentes, conhecedoras do negócio e livres de pressões ou outros interesses¹⁰.

9. Veja-se: “O ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*) gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo (...) porque não é um recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode ser mensurado com segurança ao custo”. (Trecho dos itens 48 e 49 do Pronunciamento Técnico CPC nº 4).

10. Sobre o tema, conferir a análise da Comissão de Valores Mobiliários no item 20.1.7 do Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 1/2007: “A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”. (...). Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e

A despeito do Pronunciamento Técnico CPC nº 15, é importante ressaltar que a Lei nº 6.404/1976 sempre permitiu, nos balanços individuais, o reconhecimento do lucro gerado em operações realizadas entre partes relacionadas. O artigo 250 da citada lei apenas prevê que, nas demonstrações financeiras consolidadas, é obrigatória a eliminação dos resultados ainda não realizados, em operações formalizadas entre as sociedades investidora e investida¹¹. Ora, se é obrigatório eliminar tais valores do balanço consolidado, é forçoso reconhecer que esses valores estão registrados nas demonstrações financeiras individuais¹².

Antes da edição da Lei nº 12.973/2014, não havia regra jurídica restringindo o reconhecimento do ágio em operações internas¹³. Ao contrário, sob o ponto de vista tributário, prevalecia a ideia de que as operações realizadas entre partes relacionadas deveriam seguir o mesmo tratamento tributário aplicável às operações entre partes independentes, como ocorre em relação às regras de distribuição disfarçada de lucros e de preços de transferência. Dessa forma, ainda que a contabilidade, em certas circunstâncias, não admitisse o ágio gerado internamente¹⁴, as normas

exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e, portanto, inadmissível. Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria concebível se realizada entre partes independentes, concededoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas na literatura internacional como *'arm's length'*. Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade”.

11. Confira-se: “Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas: (...) III – as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do ativo não circulante que corresponderem a resultados, ainda não realizados, de negócios entre as sociedades” (...).
12. Nesse sentido, conferir: MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. “Ágio Interno – É um mito?”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 4º Volume. Coord. Roberto Quirga Mosquera e Aleksandro Broedel Lopes. São Paulo: Dialética, 2013, pp. 95-96.
13. SCHOUERI, Luís Eduardo. *Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários)*. São Paulo: Dialética, 2012, p. 112.
14. É importante mencionar que a restrição ao reconhecimento de “ágio interno” para fim contábil não é absoluta, como ensina Edison Carlos Fernandes: “De maneira geral, a norma contábil também prevê essa restrição, porém, não de modo absoluto, como faz

jurídicas exigiam que as transações realizadas entre partes relacionadas recebessem o mesmo tratamento aplicável àquelas praticadas por partes independentes.

Apesar dessa concepção geral, deve-se reconhecer que a jurisprudência administrativa, formada no âmbito CARF, vem sendo bastante rigorosa em relação à possibilidade de amortização fiscal do ágio registrado em operação realizada dentro do mesmo grupo econômico, salvo em situações excepcionais, nas quais há efetivo pagamento de preço, bem como acionistas minoritários envolvidos no quadro societário do grupo econômico.

O problema enfrentado na maior parte dos acórdãos examinados pelo CARF envolvendo “ágios internos” está na simulação e na falta de substância das operações, e não na existência de vínculo societário entre as partes¹⁵. Por essa razão, eventual desconsideração ou requalificação das operações que envolvem a apuração de mais-valia de ativos ou de ágio somente poderia ser justificada nos casos em que não há mudança na situação jurídica e na estrutura patrimonial das partes envolvidas, independentemente do vínculo societário.

Por fim, destaque-se que o problema relativo à restrição trazida pela Lei nº 12.973/2014, que passou a vedar o aproveitamento do ágio e da mais-valia de ativos nas transações entre partes dependentes¹⁶, será examinado no Capítulo 6.

2.3. O método de aquisição

A operação de combinação de negócios deve ser contabilizada em conformidade com o “método de aquisição”, disciplinado no Pronunciamento Técnico CPC nº 15, que compreende as seguintes etapas:

- identificação do adquirente;
- determinação da data de aquisição;
- reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, dos passivos assumidos e das participações societárias de não controladores na adquirida; e
- reconhecimento e mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*) ou do ganho proveniente de compra vantajosa.

a lei tributária (...). (FERNANDES, Edison Carlos. *Impacto da Lei nº 11.638/07 sobre os Tributos e a Contabilidade*. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 154).

15. Para uma análise mais detida, vide: TAKATA, Marcos Shigueo. “Ágio Interno sem Causa ou ‘Artificial’ e Ágio Interno com Causa ou Real – Distinções Necessárias”. In: *Contravérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 3º Volume. Coord. Roberto Quiroga Mosquera e Alessandro Broedel Lopes. São Paulo: Dialética, 2012, pp. 194-214.

16. SILVEIRA, Ricardo Maito; SILVEIRA, Rodrigo Maito. “Evolução Histórica do Benefício Fiscal de Amortização do Ágio na Aquisição de Participações Societárias e a Nova Regulação Introduzida pela Lei nº 12.973/2014”. In: *Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Vol. IV*. Coord. Sergio André Rocha. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 464.

Note-se que, por privilegiar o enfoque das demonstrações financeiras consolidadas, o método da aquisição parte do pressuposto de que a aquisição do controle de uma sociedade compreende a aquisição individual da totalidade dos itens patrimoniais que formam o seu patrimônio, o que justifica o reconhecimento, pelo acionista controlador, da totalidade dos ativos e passivos da sociedade controlada, avaliados a valor justo. A participação dos acionistas minoritários é registrada diretamente no patrimônio líquido¹⁷.

2.4. Identificação do adquirente e aquisição reversa

Segundo o item 6 do Pronunciamento Técnico CPC nº 15, o primeiro passo para o registro contábil de uma operação de combinação de negócios reside na identificação do adquirente, que é entidade que obtém o controle de um negócio.

Neste ponto, pode surgir uma grande divergência entre a contabilidade e o direito tributário, tendo em vista a atual desvinculação entre o registro contábil e a natureza jurídica da operação. Por isso, a pessoa jurídica que figura como titular do investimento sob o ponto de vista jurídico pode não ser a adquirente contábil.

Para a identificação do adquirente, a contabilidade pode levar em consideração, por exemplo, a origem dos recursos utilizados na aquisição da participação societária, o porte das sociedades envolvidas, a emissão de instrumentos patrimoniais, a retenção dos direitos de votos, entre outros elementos¹⁸, distanciando-se, assim, da mera análise da propriedade jurídica.

Este distanciamento entre o direito tributário e a contabilidade fica evidente no caso da chamada “aquisição reversa”, prevista no item B19 do Pronunciamento Técnico CPC nº 15, cuja redação é a seguinte:

“B19. A aquisição reversa ocorre quando a entidade que emite os títulos (adquirente legal) é identificada como a adquirida para fins contábeis, conforme orientações constantes nos itens B13 a B18. A entidade cuja participação societária tiver sido adquirida (adquirida legal), deve ser considerada, para fins contábeis, como a adquirente para que a operação seja considerada uma aquisição reversa. (...) Contudo, pela aplicação das orientações contidas nos itens B13 a B18, o resultado da identificação do adquirente revela que:

17. CANTO, Christian Clarke de Ulhôa; RIGONI, João Marcus de Melo; HONAISSER, Thiago Cerqueira. “O Tratamento Fiscal Dispensado ao Ágio (Goodwill) Pago pelo Acionista Controlador na Aquisição de Participação Societária de Acionistas Minoritários”. In: *Direito Tributário – Estudos em Homenagem aos 60 Anos de Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados*. Coord. Rodrigo Brunelli Machado et al. Rio de Janeiro: Forense, 2019, pp. 326-327.
18. GELBCKE, Ernesto Rubens et al. *Manual de Contabilidade Societária – Aplicável a Todas as Sociedades*. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018, p. 465.

- (a) a companhia aberta é a adquirida para fins contábeis (adquirida contábil); e
- (b) a entidade fechada é o adquirente para fins contábeis (adquirente contábil).

Na operação, a adquirida contábil deve atender à definição de um negócio para ser contabilizada como aquisição reversa, bem como *são aplicáveis todos os princípios de reconhecimento e mensuração previstos neste Pronunciamento, incluindo as exigências para reconhecimento do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill).*” (g.n.)

Como se pode observar, a regra contábil apregoa que, em certas situações, poderá haver divergência entre o “adquirente jurídico” e o “adquirente contábil”, sob o enfoque da substância econômica da operação. Em vista disso, a contabilidade pode indicar como adquirente em uma combinação de negócios a pessoa jurídica que, sob o ponto de vista do direito privado, nos termos dos instrumentos contratuais firmados entre as partes, configurou como adquirida.

O artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977, ao tratar do desdobramento do custo de aquisição, não estabelece critérios para a identificação do adquirente, limitando-se a estabelecer que o contribuinte que avaliar investimento pelo MEP deverá, por ocasião da aquisição, desdobrar o custo de aquisição da participação societária.

Com base na suposta ausência de regra específica sobre o tema na legislação tributária, Sergio Bento sustenta que o critério contábil deve ser utilizado no direito tributário, sob o argumento de que o Procedimento Técnico nº 15 e as demais regras contábeis aplicáveis ao caso estão inseridos no âmbito do direito comercial, que serve como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando expressamente excepcionado pelo legislador¹⁹. Assim, na ausência de prescrição normativa específica, os critérios contábeis deveriam prevalecer.

Com a devida vênia, a interpretação defendida pelo autor não parece ser a mais acertada, pois parte da premissa de “onisciência contábil do legislador”, segundo a qual, para todos os casos não expressamente regulados pela Lei nº 12.973/2014, deve-se atribuir efeitos ao tratamento contábil, aplicando-se a legislação tributária sobre a representação contábil dos fatos ocorridos na realidade social²⁰.

A bem de ver, o artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977, mesmo após a alteração promovida pela Lei nº 12.973/2014, deve ser interpretado em linha com o

19. BENTO, Sergio. “Tratamento Tributário do Ágio”. In: *Lei 12.973/14 – Novo Marco Tributário: Padrões Internacionais de Contabilidade*. Coord. Marcelo Lima Vieira et al. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 156.

20. ROCHA, Sergio André. “Neutralidade Fiscal do Padrão IFRS Pós-Lei nº 12.973/2014”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis*. Coord. Alexandre Evaristo Pinto et al. São Paulo: Atlas, 2020, p. 365.

ordenamento jurídico no qual está inserido, pois, como alerta Eros Grau, “não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços. A interpretação de qualquer texto de direito impõe sempre ao intérprete, em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso de que projeta a partir dele – do texto – até a Constituição”²¹. Por isso, o contribuinte mencionado no artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 será aquele que, segundo o ordenamento jurídico em vigor, adquire a titularidade²² de participação societária mediante contraprestação²³.

Ademais, a contabilidade não é suficiente para determinar a ocorrência do fato jurídico tributário, tampouco para alterar as suas consequências fiscais, limitando-se a registrar e refletir os eventos ocorridos na realidade fática, de acordo com a linguagem contábil. Daí o alerta de Ricardo Mariz de Oliveira, no sentido de que “nenhum procedimento contábil pode alterar as obrigações tributárias, para mais ou para menos”²⁴.

Essa advertência é importante porque a adoção de uma contabilidade de origem anglo-saxônica, desenvolvida em um ambiente de “*common-law*” e baseada na substância econômica das operações e na perspectiva das demonstrações financeiras consolidadas, não pode incluir no ordenamento jurídico brasileiro, por via oblíqua, uma hipótese de prevalência dos efeitos econômicos sobre a forma jurídica.

O artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 possui uma hipótese normativa específica, que consiste na aquisição de um investimento avaliado pelo MEP. Na interpretação de tal dispositivo legal, não é possível se afastar da estrutura jurídica utilizada para a aquisição da participação societária, pois o direito positivo está estruturado a partir do binômio “lícito” e “ilícito”, justamente para facilitar a tomada de decisões e reduzir as zonas de incerteza na interpretação jurídica²⁵.

21. GRAU, Eros Roberto. *Por que tenho medo dos juizes: (a interpretação/aplicação do direito e os princípios)*. 9ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 86.

22. Segundo Rafael D. F. Vanzella, “(...) propriedade significa titularidade de posições jurídicas patrimoniais. (...) a Lei de Sociedade por Ações fala, em diversas passagens, em ‘propriedade de ações’; ter-se-ia referido à mesma noção, com maior rigor técnico, se houvesse dito ‘titularidade de ações’ (...)” (VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. *O Contrato e os Direitos Reais*. São Paulo: Ed. RT, 2012, pp. 82-83).

23. HADDAD, Gustavo Lian; PAES, Gustavo Duarte. “O Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura na Lei 12.973 e o Goodwill na Combinação de Negócios – Aproximações e Distanciamentos”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 6º Volume. Coord. Roberto Quirga Mosquera e Alessandro Broedel Lopes. São Paulo: Dialética, 2015, p. 260.

24. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. “A problemática das receitas de terceiros perante as bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”. In: *Direito Tributário Atual* nº 17. São Paulo: Dialética, 2003, p. 80.

25. CARVALHO, João Rafael L. Gândara de. *Forma e substância no direito tributário: legalidade, capacidade contributiva e planejamento fiscal*. São Paulo: Almedina, 2016, p. 356.

Não se ignora o fato de que a contabilidade assume certa relevância prática como instrumento para o registro das mutações patrimoniais e dos resultados apurados pelas pessoas jurídicas, que servem como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo dos tributos corporativos²⁶. Tampouco se desconhece o teor do artigo 177, § 5º, da Lei nº 6.404/1976, segundo o qual a escrituração contábil da companhia deverá observar princípios de contabilidade geralmente aceitos, bem como os padrões internacionais de contabilidade aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), como é o caso dos Pronunciamentos Contábeis. Veja-se:

“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.

(...)

§ 5º. As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o § 3º deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários” (...).

Porém, é de se reconhecer que essa delegação de competência somente é possível porque o direito comercial não está vinculado ao princípio da estrita legalidade. A contabilidade internacional segue um padrão contábil de base principiológica, no qual se atribui ampla competência decisória para o contador e para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis²⁷. Diversamente, no campo do direito tributário, o princípio da legalidade tributária exige que o fato gerador do tributo e os seus elementos sejam veiculados, com clareza e exaustividade, por meio de lei em sentido estrito. Assim, a legalidade tributária requer que todos os aspectos do fato gerador da obrigação tributária sejam estabelecidos por meio de lei formal, enquanto ato normativo emanado por órgão com competência legislativa²⁸. Daí não se concordar com a ideia de que uma regra contábil, como o Pronunciamento Técnico CPC

26. Para uma análise mais detalhada do último ponto, especificamente em relação ao uso da contabilidade como elemento de prova, conferir: CANADO, Vanessa Rahal. *COFINS – Aspectos Teóricos e Práticos*. São Paulo: Saraiva/FGV, 2011, pp. 63-68.

27. Como aponta Sergio André Rocha, “(...) a incidência tributária não pode flutuar de acordo com o entendimento deste ou daquele contador” (ROCHA, Sergio André. “Neutralidade Fiscal do Padrão IFRS Pós-Lei nº 12.973/2014”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis*. Coord. Alexandre Evaristo Pinto et al. São Paulo: Atlas, 2020, p. 352).

28. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. “O ‘Princípio da Tipicidade Tributária’ e o Mandamento de Minimização das Margens de Discrecionalidade e de Vedação da Analogia”. In: *Direito Tributário e a Constituição – Homenagem ao Professor Sacha Calmon Navarro Coelho*. Coord. Eduardo Maneira e Heleno Taveira Torres. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 653.

nº 15, poderia alterar a condição jurídica do adquirente de uma participação societária, como se competisse à contabilidade qualificar os fatos ocorridos na realidade social, não apenas para fins contábeis, mas também para fins fiscais.

Ademais, ainda que a Lei nº 6.404/1976 delegue competência para a CVM para a edição de atos normativos contábeis, é evidente que essas regras contábeis subalternas não podem ultrapassar os limites legais, alterando critérios estabelecidos por meio de lei em sentido estrito. Assim, os poderes concedidos aos órgãos administrativos para regulamentar a matéria contábil não chegam ao ponto de permitir a alteração de critérios estabelecidos em lei, pois isso implicaria não apenas a violação da hierarquia normativa do sistema jurídico, mas também a supressão da competência legislativa do Congresso Nacional²⁹.

Daí decorre que, embora a Lei nº 12.973/2014 tenha alterado de forma substancial o regime jurídico do desdobramento do custo de aquisição de participações societárias, fato é que determinados conceitos basilares do direito privado permanecem inalterados para fins fiscais, entre os quais os de “adquirente” e de “aquisição”, que conservaram a sua definição jurídica, tal como prevista no direito privado.

Assim, no caso da chamada “aquisição reversa”, para fins tributários, o custo de aquisição deve ser desdobrado pela pessoa jurídica que detém a propriedade jurídica sobre a participação societária, sendo irrelevante o tratamento conferido pela contabilidade à operação para fins de determinação do “adquirente contábil”. O fato de haver uma distinção entre o “adquirente contábil” e o “adquirente jurídico”, sob o ponto de vista da substância econômica, não foi tido como relevante pela Lei nº 12.973/2014.

Diante disso, para conciliar as divergências de critérios, a única solução possível consiste na elaboração de um laudo de avaliação (PPA) específico para fins fiscais, com a alocação da contraprestação segundo a qualificação jurídica da operação. Nessa hipótese, a sociedade investida no âmbito do direito privado deverá ter seus ativos e passivos mensurados a valor justo, para fins de determinação do valor do ágio ou do ganho por compra vantajosa, que será considerado apurado sob o ponto de vista jurídico³⁰.

2.5. Definição da data de aquisição

A correta determinação da data de aquisição da participação societária é relevante, principalmente para a identificação do balanço patrimonial da sociedade

29. ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. *Imposto de Renda das Empresas*. 12ª Edição. São Paulo: Atlas, 2016, p. 105.

30. VIEIRA, Jorge. Combinação de Negócios e os impactos societários e tributários das IFRSs no Brasil: desafios apresentados aos operadores do Direito e aos operadores das IFRSs”. *Revista Direito GV*, v. 14, n. 2, São Paulo: FGV, 2018, p. 568.

investida, que determinará o patrimônio líquido de referência³¹, bem como para a definição do termo inicial de contagem do prazo de 13 (trezes) meses para o protocolo do laudo de avaliação perante a Receita Federal do Brasil ou registro do seu sumário no Cartório de Registro de Títulos e Documentos³².

A dúvida a respeito da data de aquisição surge porque as operações de fusões e aquisições são estruturadas em várias etapas sucessivas, que se desenvolvem por um período prolongado, tais como: a assinatura do acordo de confidencialidade; a assinatura de um memorando de entendimentos; a assinatura do contrato de compra e venda de cotas ou de ações (i.e. “*Quota Purchase Agreement*” ou “*Share Purchase Agreement*”); e a assinatura do ato de fechamento da operação, no qual ocorre o pagamento do preço acordado e a transferência da titularidade das quotas ou ações.

Além disso, em inúmeros casos, há a necessidade de aprovação da combinação de negócios pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), no contexto da disciplina concorrencial de concentração econômica.

A dificuldade surge porque, para a contabilidade, o momento da transferência jurídica da titularidade das cotas ou ações não é determinante. De um lado, a contabilidade pode efetuar o reconhecimento da participação societária antes da transferência jurídica da propriedade, deixando de considerar, por exemplo, eventual condição suspensiva inserida no instrumento contratual. De outro lado, a contabilidade pode reconhecer a participação societária após a transferência jurídica da propriedade, caso se entenda que o adquirente ainda não comanda a exploração das utilidades e negócios da empresa adquirida e os seus benefícios econômicos futuros.

Isso sem contar que o regime jurídico de transferência de participações societárias é distinto daquele aplicável ao trespasse de estabelecimento e outras aquisições de negócios³³, o que também pode exercer influência sobre o momento do reconhecimento contábil da operação de combinação de negócios, com a consequente alocação do preço de aquisição e a avaliação dos ativos e passivos a valor justo.

Sob o enfoque tributário, o artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 faz alusão à data de aquisição da participação societária na pessoa jurídica investida, ao tratar da avaliação do investimento pelo MEP e do desdobramento do custo de aquisição em valor do patrimônio líquido, mais ou menos-valia de ativos líquidos e ágio por rentabilidade futura ou ganho proveniente de compra vantajosa.

No caso de sociedade controlada, o registro inicial do investimento com base no MEP ocorre a partir do momento da caracterização de controle societário,

31. Artigo 20, inciso I, do Decreto-Lei nº 1.598/1977

32. Artigo 20, § 3º, do Decreto-lei nº 1.598/1977.

33. BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. *Compra e Venda de Participações Societárias de Controle*. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 427.

assim entendido a titularidade de direitos de sócios que assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores³⁴. O artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 pressupõe a hipótese de investimento que, ao ser adquirido, preenche os requisitos para a sua avaliação pelo MEP, mas nada impede que o desdobramento seja efetuado na data em que for iniciada a aplicação do referido método de avaliação, como, aliás, defendiam Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira na vigência da redação original desse preceito normativo³⁵.

Note-se que a lei societária não estabelece um percentual mínimo de ações votantes para a caracterização da figura do acionista controlador, optando por uma análise baseada no efetivo exercício do poder de direção das atividades sociais³⁶. Assim, em caso de sociedades com elevada dispersão de suas ações no mercado, um acionista pode exercer o poder de controle com menos da metade do capital votante, em virtude da inexistência de outro acionista com maior número de ações com direito a voto³⁷.

Daí se dizer que o conceito de controle do direito societário abre certa margem para a investigação da realidade dos fatos, tendo em vista que o artigo 116, alínea “b”, da Lei nº 6.404/1976 prevê que, além de ser titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia (alínea a), o acionista controlador também deve efetivamente usar o seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

A seu turno, o registro inicial do investimento em sociedade coligada com base no MEP ocorre quando restar caracterizada a influência significativa, por meio da qual a pessoa jurídica investidora detém o poder de participar nas deliberações relativas às políticas financeiras ou operacionais da sociedade investida, sem

34. O conceito de sociedade controlada está previsto no artigo 243, § 2º, da Lei nº 6.404/1976, segundo o qual a sociedade controlada é a pessoa jurídica na qual a sociedade controladora, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Assim, o acionista controlador utiliza seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

35. LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. *Direito das Companhias*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 1424-1425.

36. Nas palavras de Nelson Eizirik: “A Lei das S.A. reconhece a existência do poder de controle acionário nas sociedades anônimas, definindo-o não em função da titularidade da maioria do capital votante, mas em virtude do efetivo exercício da direção das atividades sociais” (EIZIRIK, Nelson. *A Lei das S/A Comentada – Artigos 80 ao 137*. Volume 2. 2ª Edição. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 223).

37. EIZIRIK, Nelson. *A Lei das S/A Comentada – Artigos 206 ao 300*. Volume 4. 2ª Edição. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 201.

controlá-la³⁸. Segundo o artigo 243, § 5º, da Lei nº 6.404/1976, a influência significativa será presumida quando a pessoa jurídica investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida.

Diante disso, percebe-se que a referência feita pelo artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 à data de aquisição da participação societária deve ser compreendida no contexto da avaliação do investimento pelo MEP, o que pressupõe a caracterização do controle societário ou a verificação da influência significativa³⁹.

2.6. Reconhecimento

De acordo com o item 10 do Pronunciamento Técnico CPC nº 15, “o adquirente deve reconhecer, separadamente do ágio por expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*), os ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e quaisquer participações de não controladores na adquirida”.

Para tanto, os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos devem atender às definições de ativo e de passivo dispostas no Pronunciamento Conceitual Básico, que estão redigidas nos seguintes termos:

- ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos;
- passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos.

É importante mencionar que, nas operações de combinação de negócios, o adquirente pode reconhecer ativos e passivos que não haviam sido anteriormente reconhecidos nas demonstrações contábeis da sociedade adquirida (“*off-balance sheet*”), como os ativos e os passivos contingentes⁴⁰, bem como os ativos intangíveis desenvolvidos internamente (v.g. a marca desenvolvida internamente, que não é reconhecida como ativo nas demonstrações contábeis da sociedade adquirida, em razão do registro dos dispêndios relacionados à sua criação e divulgação como despesas).

Assim, o conceito de ativo identificável alcança não apenas os ativos registrados na contabilidade da sociedade investida, mas também os ativos não contabilizados, como prevê o item 13 do Pronunciamento Técnico CPC nº 15. Veja-se:

38. Artigo 243, §§ 1º e 4º, da Lei nº 6.404/1976

39. LOPES, Roberto Salles; SANTOS, Laura Diniz Silva. “A Data de Aquisição e as Operações Intragrupo para Fins Tributários no Período Pós-IFRS”. In: *Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A*. Volume V. Coord. Sergio André Rocha. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 485.

40. ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. “O Regime Jurídico Tributário da Mais-Valia sobre Investimentos e do Ágio por Rentabilidade Futura na Vigência da Lei nº 12.973/2014”. In: *Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Vol. IV*. Coord. Sergio André Rocha. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 141.

“A aplicação do princípio e as condições de reconhecimento pelo adquirente podem resultar no reconhecimento de alguns ativos e passivos que não tenham sido anteriormente reconhecidos como tais nas demonstrações contábeis da adquirida. Por exemplo, o adquirente reconhece os ativos intangíveis identificáveis adquiridos como uma marca ou uma patente ou um relacionamento com clientes, os quais podem não ter sido reconhecidos como ativos nas demonstrações contábeis da adquirida por terem sido desenvolvidos internamente e os respectivos custos terem sido registrados como despesa” (g.n.).

Sob o ponto de vista contábil, o ágio de rentabilidade futura corresponde à parcela do custo de aquisição que excede o valor justo dos ativos líquidos tangíveis e intangíveis identificáveis. Assim, no âmbito da ciência contábil, o ágio de rentabilidade futura corresponde à capacidade de geração de lucros que não pode ser atribuída a um item patrimonial específico, passível de negociação individual. É o que ensinam Eliseu Martins e Sérgio de Iudícibus, na passagem a seguir transcrita:

“Ágio por rentabilidade futura é um ativo que representa benefícios econômicos futuros resultados dos ativos adquiridos em combinação de negócios, os quais não são individualmente identificados ou separadamente reconhecidos.”⁴¹

Logo, o ágio por rentabilidade futura corresponde à parcela do preço de aquisição que não pode ser alocada a ativos passíveis de identificação individual e de reconhecimento segregado nas demonstrações financeiras. Daí se dizer que a noção de ágio está relacionada à sinergia obtida com a exploração conjunta dos bens e direitos que compõem o patrimônio empresarial, tendo em vista que os ativos da empresa adquirida, utilizados de forma agregada, proporcionam benefícios econômicos superiores aos que seriam obtidos com o emprego individual de cada bem.

Nesse sentido, o item 11 do Pronunciamento Técnico CPC nº 4 (“ativos intangíveis”) destaca expressamente a relação do ágio de rentabilidade futura com a sinergia entre os ativos identificáveis adquiridos na combinação de negócios, bem como com ativos que, individualmente, não atendem aos critérios para o seu reconhecimento em separado nas demonstrações contábeis. Confira-se a redação da regra contábil:

“A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, para diferenciá-lo do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill). O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido em uma combinação de negócios é um ativo que representa benefícios econômicos

41. MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. “Intangível – sua Relação Contabilidade/Direito – Teoria, Estruturas Conceituais e Normas – Problemas Fiscais de Hoje”. In: *Contravérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 2º Volume. Coord. Roberto Quiroga Mosquera e Alessandro Broedel Lopes. São Paulo: Dialética, 2011, p. 79.

futuros gerados por outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios, que não são identificados individualmente e reconhecidos separadamente. Tais benefícios econômicos futuros podem advir da sinergia entre os ativos identificáveis adquiridos ou de ativos que, individualmente, não se qualificam para reconhecimento em separado nas demonstrações contábeis” (g.n.).

Dessa forma, o ágio por rentabilidade futura pode estar relacionado a inúmeros fatores, como a localização da empresa, a fidelidade dos clientes, a reputação comercial, a fatia de mercado (“*market share*”) conquistada, a qualidade da administração, o treinamento dos profissionais, o conhecimento tecnológico, a capacidade mercadológica, entre outros efeitos sinérgicos oriundos dos ativos da sociedade adquirida⁴². Diante do seu caráter residual, pode-se afirmar que o ágio de rentabilidade futura representa uma aptidão adicional para a geração de lucros, decorrente da exploração conjunta de bens e direitos que compõem determinado empreendimento.

2.7. Mensuração

A Lei nº 12.973/2014 não estabeleceu parâmetros específicos para a mensuração do valor justo dos ativos e passivos assumidos na combinação de negócios, o que remete o intérprete à disciplina contábil. Trata-se, assim, de hipótese de *remissão externa*⁴³, por meio da qual o legislador estabelece uma *abertura cognitiva*⁴⁴ à ciência contábil, ainda que com recortes metodológicos próprios do sistema jurídico⁴⁵.

Segundo o item 18 do Pronunciamento Técnico CPC nº 15, no contexto do “método de aquisição”, “o adquirente deve mensurar os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos pelos respectivos valores justos na data da aquisição”.

Sob o ponto de vista contábil, desde a edição da Lei nº 11.638/2007, que introduziu as regras internacionais de contabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, o registro contábil baseado no *custo de aquisição* tem perdido a sua importância na mensuração dos valores apresentados no balanço patrimonial e na

42. LOPES, Alessandro Broedel; MARTINS, Eliseu. “Do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura – Algumas Considerações Contábeis”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 3º Volume. Coord. Roberto Quiroga Mosquera e Alessandro Broedel Lopes. São Paulo: Dialética, 2012, p. 37.

43. Trata-se de hipótese também denominada de “reenvio direto” (Cf. FONSECA, Fernando Daniel de Moura. *Normas Tributárias e a Convergência das Regras Internacionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, pp. 96 – 100; DELGADO, Carlos Henrique Crosara. *Contabilidade IFRS e IRPJ: efeitos da nova contabilidade internacional sobre a tributação da renda*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 74).

44. Sobre o tema, vide: LUHMANN, Niklas. *Law as a Social System*. Oxford: Oxford University, 2004, pp. 99-103.

45. VILANOVA, Lourival. *As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo*. São Paulo: Noeses, 2006, p. 42.

demonstração de resultados, em razão da própria evolução do mercado de capitais. O critério do *custo de aquisição* como base para as mensurações se justificava em um momento histórico em que o direito comercial e a disciplina das demonstrações financeiras tinham o objetivo de preservar os interesses dos credores, como forma de evitar avaliações patrimoniais irreais e a constituição de reservas ocultas. Com a introdução do padrão internacional de contabilidade, o valor justo passou a ser adotado, em diversas situações, como o critério para a mensuração de ativos e passivos, em razão da maior preocupação da contabilidade com o interesse dos investidores e do mercado em geral⁴⁶.

O regime contábil para a determinação do valor justo deve seguir as disposições do Pronunciamento Técnico CPC nº 46, que estabelece os critérios para a sua mensuração. Em geral, a mensuração de ativos a valor justo corresponde a uma estimativa de preços dos ativos adquiridos em uma transação não forçada entre partes independentes, sob condições atuais de mercado. Logo, como a contabilidade privilegia o desempenho econômico da entidade, a partir de uma visão prospectiva do seu patrimônio, é natural que os ativos e passivos adquiridos sejam avaliados a valor justo, como forma de privilegiar uma mensuração baseada no mercado.

Além disso, o Pronunciamento Técnico CPC nº 15 prevê que o adquirente deve mensurar os componentes da participação de não controladores na sociedade adquirida, que confirmam a seus detentores uma participação proporcional em seus ativos líquidos em caso de sua liquidação, por um dos seguintes critérios: (a) pelo valor justo; ou (b) pela participação proporcional atual conferida pelos instrumentos patrimoniais nos montantes reconhecidos dos ativos líquidos identificáveis da adquirida (item 19).

A mensuração do ágio de rentabilidade futura pode sofrer grande impacto em razão dos novos critérios contábeis, sobretudo, em virtude da necessidade de que o patrimônio da investida seja levado a valor justo antes do reconhecimento do valor residual relativo ao sobrepreço pago na aquisição do investimento. Segundo Valter de Souza Lobato, em razão da tendência de que o valor justo supere o custo histórico dos ativos e passivos da investida, é natural que o sobrepreço passível de reconhecimento como ágio seja sensivelmente diminuído. Esse cenário é acentuado pelo fato de que os ativos líquidos não registrados no patrimônio da sociedade investida passam a ser mensurados a valor justo por ocasião da combinação de negócios⁴⁷⁻⁴⁸. Isso pode ocorrer, por exemplo, no caso de ativos intangíveis não

46. ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. *Imposto de Renda das Empresas*. 12ª Edição. São Paulo: Atlas, 2016, pp. 58-59.

47. LOBATO, Valter de Souza. "Capítulo 4 – O Novo Regime Jurídico do Ágio na Lei 12.973/2014". In: *O Ágio no Direito Tributário e Societário – Questões Atuais*. Coord. Eduardo Maneira e Igor Mauler Santiago. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 106.

48. Vide item 19 do Pronunciamento Técnico CPC nº 15: "Em cada combinação de negócios, o adquirente deve mensurar, na data da aquisição, os componentes da participação de não

reconhecidos na escrituração contábil da investida, por terem sido desenvolvidos internamente e os respectivos dispêndios lançados como despesas.

Assim, no regime anterior, o ágio correspondia à mera diferença entre o valor do patrimônio líquido da investida e o custo do investimento, podendo ser justificado com base em três diferentes critérios (mais-valia de ativos, expectativa de rentabilidade futura e fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas).

Por outro lado, no regime jurídico da Lei nº 12.973/2014, apenas a diferença entre o custo de aquisição e o valor justo dos ativos e passivos da investida será reconhecida como ágio de rentabilidade futura⁴⁹. Logo, a mais-valia dos ativos, quando existente, deve ser alocada diretamente aos bens ou direitos que a geraram, ao passo que os ativos intangíveis devem ser reconhecidos e avaliados com base no valor justo. Apenas no final do processo de alocação do preço, caso ainda exista alguma diferença, o valor correspondente poderá ser contabilizado como ágio de rentabilidade futura⁵⁰.

Note-se que, caso o custo de aquisição do investimento seja inferior à soma do valor do patrimônio líquido da sociedade investida e a mais ou menos valia de ativos e passivos, na proporção da participação societária adquirida, não haverá ágio por expectativa de rentabilidade futura, mas, sim, a apuração de ganho proveniente de compra vantajosa.

2.8. Os ativos e passivos fiscais diferidos

Como visto anteriormente, o Pronunciamento Técnico CPC nº 15 determina que os ativos adquiridos e os passivos assumidos sejam mensurados pelos respectivos valores justos da data da aquisição.

Neste contexto, segundo o item 23 da Intepretação Técnica ICPC nº 09 e o item 19 do Pronunciamento Contábil CPC nº 32 (Tributos sobre o Lucro), por ocasião do registro do valor justo dos ativos líquidos, o adquirente deverá reconhecer o ativo ou o passivo fiscal diferido correspondente aos efeitos tributários das

controladores na adquirida que representem nessa data efetivamente instrumentos patrimoniais e confirmam a seus detentores uma participação proporcional nos ativos líquidos da adquirida em caso de sua liquidação, por um dos seguintes critérios: (a) pelo valor justo, ou (b) pela participação proporcional atual conferida pelos instrumentos patrimoniais nos montantes reconhecidos dos ativos líquidos identificáveis da adquirida”.

49. RIBEIRO, Ricardo Lodi; SANTOS, Flávio Mattos dos. “Natureza Jurídica da Amortização Fiscal do Ágio: despesa necessária, benefício fiscal ou norma antielísiva”. In: *O Ágio no Direito Tributário e Societário*. Coord. Eduardo Maneira e Igor Mauler Santiago. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 27.

50. LOBATO, Valter de Souza. “Capítulo 4 – O Novo Regime Jurídico do Ágio na Lei 12.973/2014”. In: *O Ágio no Direito Tributário e Societário – Questões Atuais*. Coord. Eduardo Maneira e Igor Mauler Santiago. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 106-107.

diferenças entre as bases fiscais dos ativos ou passivos no balanço patrimonial da entidade adquirida e os seus valores justos, lançados como mais ou menos-valia de ativos, na conta de investimento da entidade adquirente. Isso é assim porque, para garantir maior transparência e fidedignidade nas demonstrações financeiras, as regras contábeis baseadas no padrão IFRS exigem a divulgação das despesas tributárias correntes e diferidas, com base no saldo das diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis⁵¹.

A diferença temporária surge quando o valor contábil de um ativo ou passivo é diferente daquele que lhe atribui, em determinado período-base, o direito tributário, o que pode gerar um *passivo fiscal diferido* ou um *ativo fiscal diferido*. O primeiro surge na presença de uma diferença temporária tributável, ao passo que o segundo surge diante de uma diferença temporária dedutível⁵².

No caso das combinações de negócios, o racional que orienta o reconhecimento de um *passivo fiscal diferido* ou de um *ativo fiscal diferido* resulta do fato de que o valor dos benefícios econômicos esperados para o ativo, ou da saída de recursos esperada para a liquidação do passivo, deve ser refletido na entidade adquirente com base no montante líquido do efeito tributário, isto é, após a devida consideração do impacto do IRPJ e da CSLL⁵³.

Com efeito, quando o valor contábil de um ativo no balanço patrimonial é maior que a sua base fiscal, o valor dos benefícios econômicos esperados para o ativo excede o valor que será permitido como dedução para fins fiscais no momento da sua realização. Essa “diferença temporária” acarreta o registro de um *passivo fiscal diferido*, correspondente ao valor dos tributos que serão devidos em período

51. CHARNESKI, Heron. *Normas Internacionais de Contabilidade e Direito Tributário Brasileiro*. Série Doutrina Tributária. Volume XXIV. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 71.

52. CHARNESKI, Heron. *Normas Internacionais de Contabilidade e Direito Tributário Brasileiro*. Série Doutrina Tributária. Volume XXIV. São Paulo: Quartier Latin, 2018, pp. 67-69.

53. É o que ensina Edmar Oliveira de Andrade Filho: “A apuração de mais-valia evidencia que os ativos líquidos podem gerar (em perspectiva) benefícios econômicos e financeiros superiores aos reconhecidos no Balanço da sociedade investidora, por isso, a mais-valia é um indicativo de lucros potenciais atrelados a esses ativos líquidos, razão pela qual, nos valores resultantes da avaliação devem ser considerados os tributos incidentes sobre a mais-valia, inclusive os que recaem sobre o lucro, como o IRPJ e a CSL. Se a investidora fizesse a avaliação de seus próprios bens com base no valor justo, não deveria considerar os tributos sobre o lucro; todavia, considerando que a avaliação, nesse caso, recai sobre bens de outrem, o critério a ser adotado é o que embasa o método da equivalência patrimonial, posto que os benefícios econômicos futuros a serem hauridos eventualmente pela investidora serão sempre líquidos, ou sejam impactados por tributos sobre o lucro” (ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. “O regime jurídico tributário da mais-valia sobre investimentos e do ágio por rentabilidade futura na vigência da Lei n. 12.973/2014”. In: *Direito tributário, societário e a reforma da Lei das S/A*. Volume IV. Sergio André Rocha. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 145).

futuro sobre a diferença tributável⁵⁴. O raciocínio inverso se aplica ao reconhecimento do *ativo fiscal diferido*, que é formado quando a base fiscal de determinado ativo ou passivo supera o seu valor justo atribuído. Em ambos os casos, têm-se uma espécie de *dissonância temporal* entre as regras contábeis e fiscais⁵⁵.

O reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos, em razão dos ajustes de natureza temporária, encontra justificativa no regime de competência e na necessidade de apresentação da alíquota efetiva dos tributos sobre o lucro com base no seu efeito econômico, independentemente do desembolso de caixa. Assim, além de equalizar os efeitos temporários dos tributos sobre o lucro, a constituição dos ativos e passivos fiscais diferidos permite uma análise mais fidedigna dos fluxos de caixa futuros⁵⁶.

Com relação às combinações de negócios, o item 66 do Pronunciamento Técnico CPC nº 32, ao tratar do tema, determina que a entidade adquirente deve reconhecer quaisquer ativos ou passivos fiscais diferidos como ativos e passivos identificáveis na data da aquisição, que devem ser demonstrados no laudo de avaliação. Veja-se:

“Conforme explicado nos itens 19 e 26(c), diferenças temporárias podem surgir em combinação de negócios. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 15 – Combinação de Negócios, a entidade deve reconhecer quaisquer ativos fiscais diferidos resultantes (na medida em que tais ativos fiscais atendam aos critérios de reconhecimento do item 24) ou passivos fiscais diferidos como ativos e passivos identificáveis na data da aquisição. Consequentemente,

54. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC nº 32, a “diferença temporária” é definida como “a diferença entre o valor contábil de ativo ou passivo no balanço e a sua base fiscal” (item 5), sendo a “base fiscal” de ativo ou passivo “o valor atribuído àquele ativo ou passivo para fins fiscais” (item 5). A diferença temporária surge, assim, quando o valor contábil de um elemento do patrimônio (ativo ou passivo) é diferente daquele que lhe atribui, em determinado período-base, a regra tributária, o que causa diferenças no montante da renda apurada sob o enfoque de cada ciência, mas que devem ser revertidas ao longo do tempo. A diferença temporária é denominada tributável quando resultar em valores tributáveis na determinação de resultados tributáveis de períodos futuros. Nesse caso, há o reconhecimento de um passivo fiscal diferido. Já a diferença temporária é denominada dedutível quando resultar em valores dedutíveis na determinação de resultados tributáveis em período futuros. Nesse caso, se for provável a existência de lucros tributáveis futuros, há a constituição de um ativo fiscal diferido, correspondente ao valor dos mesmos tributos que serão recuperados em período futuro sobre a diferença dedutível.

55. CHARNESKI, Heron. *Normas Internacionais de Contabilidade e Direito Tributário Brasileiro*. Série Doutrina Tributária. Volume XXIV. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 69.

56. KUNIYUKI, Cesar Pedroni. “Tributos sobre o Lucro – Ativos e Passivos Fiscais Diferidos nas Demonstrações Financeiras pelas Normas Internacionais de Contabilidade”. In: *Direito Tributário Internacional – Aspectos Práticos*. 2º Volume. Coord. Marco Antônio Chazaine Pereira. São Paulo: LTr, 2014, p. 181.

aqueles ativos fiscais diferidos e passivos fiscais diferidos afetam o valor do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*) ou ganho na compra que a entidade reconhece. Entretanto, de acordo com o item 15(a), a entidade não deve reconhecer passivos fiscais diferidos advindos de reconhecimento inicial do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*).”

Assim, na composição do acervo líquido avaliado a valor justo, os ativos ou passivos fiscais diferidos afetarão, matematicamente, o valor do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*) ou do ganho por compra vantajosa que a entidade adquirente reconhece de forma residual⁵⁷.

Dessa forma, como a Lei nº 12.973/2014 não estabelece parâmetros específicos para a mensuração do valor justo dos ativos e passivos assumidos na combinação de negócios, os efeitos reflexos dos ativos ou passivos fiscais diferidos no montante do ágio ou do ganho por compra vantajosa podem produzir efeitos fiscais⁵⁸. Trata-se, assim, de mais uma hipótese de *remissão externa*⁵⁹ prevista na Lei nº 12.973/2014, por meio da qual o legislador estabelece uma *abertura cognitiva* à ciência contábil⁶⁰⁻⁶¹.

Logo, em uma combinação de negócios, a pessoa jurídica adquirente deve reconhecer quaisquer ativos ou passivos fiscais diferidos como ativos e passivos identificáveis na data da aquisição⁶². Consequentemente, esses ativos ou passivos fiscais diferidos podem afetar o valor do ágio de rentabilidade futura ou do ganho por compra vantajosa, que apresentam caráter residual⁶³ no regime da Lei nº 12.973/2014.

57. IUDÍCIBUS Sérgio de et al. *Manual de contabilidade societária*. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018, p. 213.

58. HADDAD, Gustavo Lian; ABRANTES, Emmanuel Garcia. “Lacunas no Tratamento Fiscal da Mais ou Menos-Valia de Ativos e Passivos na Aquisição de Participação Societária – Proposta de Solução”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis*. Coord. Alexandre Evaristo Pinto et al. São Paulo: Atlas, 2020, pp. 161-162.

59. FONSECA, Fernando Daniel de Moura. *Normas Tributárias e a Convergência das Regras Internacionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, pp. 96-100; DELGADO, Carlos Henrique Crosara. *Contabilidade IFRS e IRPJ: efeitos da nova contabilidade internacional sobre a tributação da renda*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 74.

60. Como ensina Misabel Derzi, o direito constitui um sistema normativo fechado operacionalmente e aberto cognitivamente (cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. *Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário*. São Paulo: Noeses, 2009, p. 26).

61. Para uma análise mais detida, conferir: VILANOVA, Lourival. *As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo*. São Paulo: Noeses, 2006, p. 42.

62. Vide item 66 do Pronunciamento Técnico CPC nº 32.

63. IUDÍCIBUS, Sérgio de et al. *Manual de contabilidade societária*. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 213.

Marcelo Natale e Alexandre G. Querquilli defendem que, como o ativo ou passivo fiscal diferido não está associado à mais ou menos-valia de um ativo ou passivo existente no patrimônio da sociedade investida, o valor correspondente não deveria ser computado para fins de desdobramento do custo de aquisição, por ser um impacto decorrente das diferenças entre as bases contábeis e fiscais no patrimônio da pessoa jurídica adquirente⁶⁴. A interpretação preconizada por tais autores parece encontrar apoio no artigo 20, inciso II, do Decreto-lei nº 1.598/1997, que define a mais ou menos-valia como a “diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida”. Daí decorre que ativos e passivos fiscais diferidos reconhecidos pela pessoa jurídica adquirente, por conta de diferenças entre as bases contábeis e fiscais, não deveriam ser considerados.

De qualquer forma, trata-se de uma discussão complexa, tendo em vista que o legislador tributário não disciplinou a mensuração da mais ou menos-valia de ativos líquidos, fazendo remissão à disciplina contábil. Logo, caso os ativos e passivos fiscais diferidos afetem o valor da mais ou menos-valia de ativos líquidos e do ágio no momento do registro do investimento avaliado pelo MEP, o lançamento de eventuais diferenças em subcontas distintas não seria suficiente para afastar a aplicação dos parâmetros contábeis de mensuração do valor justo dos ativos e passivos assumidos.

Além disso, embora os tributos diferidos decorram dos impactos das diferenças temporárias entre as bases contábeis e fiscais nos resultados da pessoa jurídica adquirente, não há como negar que a regra contábil que exige o reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos no laudo de avaliação da combinação de negócios está em linha com a lógica do MEP, que orienta o artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977, no qual se reflete a participação da sociedade investidora no patrimônio líquido da sociedade investida pelo valor líquido, após o pagamento dos tributos sobre o lucro.

2.9. Participação societária com patrimônio líquido negativo

Segundo o artigo 20, incisos I, II e III, do Decreto-lei nº 1.598/1977, o contribuinte que avaliar investimento de acordo com o MEP deverá desdobrar o custo de aquisição entre o valor de patrimônio líquido na época da aquisição, mais ou menos-valia de ativos líquidos e o ágio por rentabilidade futura ou ganho por compra vantajosa.

64. NATALE, Marcelo; QUERQUILLI, Alexandre Garcia. “Aspectos Relevantes do Desdobramento do Custo de Aquisição de Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido”. In: *Impactos Tributários Decorrentes da Adoção do IFRS no Brasil: Uma Década de Debates*. Coord. Giancarlo Chamma Matarazzo e Luiz Felipe Centeno Ferraz. São Paulo: Blucher, 2019, p. 61.

O valor do patrimônio líquido na época da aquisição será determinado com base em balanço patrimonial levantado na mesma data do balanço patrimonial do contribuinte ou até, no máximo, 2 (dois) meses antes, sendo que, no caso de ausência de uniformidade entre os padrões contábeis, o contribuinte deverá fazer os ajustes necessários para eliminar as diferenças relevantes decorrentes da diversidade de critérios (artigo 21, incisos I e II, do Decreto-lei nº 1.598/1977).

O artigo 178, § 2º, inciso III, da Lei nº 6.404/1976, com redação dada pelo artigo 37 da Lei nº 11.941/2009, estabelece que o patrimônio líquido está subdividido em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Antes da edição da Lei nº 11.638/2007, o patrimônio líquido também compreendia a conta contábil de lucros acumulados. Atualmente, essa conta contábil tem natureza transitória, tendo em vista que, no final do exercício social, o valor total nela registrado deve ser transferido para as reservas de lucros ou utilizado para as destinações de resultados.

Assim, o patrimônio líquido, utilizado para a aplicação do MEP, corresponde a um conceito jurídico-contábil extraído da Lei nº 6.404/1976, cuja expressão numérica está refletida do balanço patrimonial da sociedade. Por essa razão, não parece ser possível utilizar a suposta distinção técnico-contábil entre os conceitos de “patrimônio líquido” e de “passivo a descoberto” para impedir que a cifra negativa interfira no cálculo do ágio.

Observe-se que a Lei nº 6.404/1976 não admite, sequer implicitamente, qualquer distinção entre “patrimônio líquido” e “passivo a descoberto”. Não há qualquer indicação, na Lei das S/A, de que o patrimônio líquido apenas pode apresentar expressão positiva. Ao contrário, na estrutura da lei societária, o patrimônio líquido pode apresentar valor positivo, nulo ou negativo.

É justamente por isso que a expressão “passivo a descoberto” deve ser compreendida como um simples jargão utilizado pelos profissionais da área contábil, que serve para indicar que o valor dos bens e direitos da pessoa jurídica (ativo) é inferior às obrigações contraídas com terceiros (passivo). Trata-se, portanto, de nomenclatura utilizada no âmbito da ciência contábil para expressar de forma mais clara a situação patrimonial da sociedade, mas que em nenhum momento foi incorporada ao direito societário brasileiro como um conceito técnico específico. Vale dizer, as normas jurídicas que disciplinam a elaboração das demonstrações financeiras, seja na Lei das S/A, seja no Código Civil, não adotam um conceito próprio de “passivo a descoberto”, que serviria para justificar a sua distinção em relação ao “patrimônio líquido”.

É bem verdade que, durante a vigência da Resolução CFC nº 1.049/2005, revogada pela Resolução CFC 1.283/2010, recomendava-se a substituição da rubrica “patrimônio líquido” pela expressão “passivo a descoberto” nos casos em que o valor das obrigações da pessoa jurídica com terceiros era superior à expressão econômica dos seus ativos (art. 1º, item 3.2.2.1, c).

Isso jamais significou, porém, que o conceito de patrimônio líquido previsto na Lei nº 6.404/1976 não pode apresentar valor negativo. Independentemente de eventuais discussões a respeito da (suposta) maior adequação técnica da expressão “passivo a descoberto”, a verdade é que as normas jurídicas não exigem que o patrimônio líquido sempre apresente situação líquida positiva. Tanto isso é verdade que, desde a edição da Resolução do CFC nº 1.283/2010, não se utiliza mais a nomenclatura “passivo a descoberto” nas demonstrações contábeis, para designar a hipótese em que o patrimônio líquido apresenta valor negativo. Se a diferenciação entre os conceitos decorresse da Lei nº 6.404/1976, é certo que a Resolução do CFC nº 1.283/2010 não poderia ter efetuado a respectiva mudança de nomenclatura sem alteração legislativa.

Firmada a premissa de que o conceito de patrimônio líquido deve ser interpretado à luz da Lei nº 6.404/1976, que não faz qualquer distinção entre *patrimônio líquido* e *passivo a descoberto*, pode-se retornar à análise do artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977.

Segundo esse preceito normativo, o contribuinte deve, na primeira avaliação do investimento pelo MEP, desdobrar o custo de aquisição, indicando o valor do patrimônio líquido, a mais ou menos-valia de ativos líquidos e o ágio de rentabilidade futura. Se, no momento da aquisição do investimento, o valor do patrimônio líquido da sociedade investida apresentar valor negativo, a diferença entre o preço de aquisição e o valor patrimonial negativo deverá ser objeto de alocação pela sociedade adquirente.

Sob o enfoque contábil, o saldo inicial da conta de investimento, no âmbito do MEP, deve ser credor nos casos em que a sociedade investida apresentar patrimônio líquido negativo. Essa forma de contabilização permite uma evidenciação mais apropriada do reflexo dos futuros resultados positivos da sociedade investida na pessoa jurídica investidora. Isso porque, caso a sociedade investidora não registre o valor negativo (saldo credor) na conta contábil de registro do investimento, as oscilações positivas no valor patrimonial da sociedade investida não serão refletidas até que o investimento atinja o valor zero. Daí se dizer que a evidenciação do saldo credor na conta contábil de registro inicial do investimento está mais alinhada com a própria finalidade da ciência contábil, na medida em que permite um maior controle do resultado econômico do empreendimento, fornecendo informações mais adequadas e transparentes aos usuários das demonstrações contábeis. Trata-se, assim, de procedimento contábil alinhado à própria essência do MEP, cujo objetivo consiste em identificar e registrar, com base no regime de competência, as mutações patrimoniais da sociedade investida e os seus reflexos na sociedade investidora⁶⁵⁻⁶⁶.

65. MARTINS, Eliseu; SZUSTER, Natan. “Compra de empresa com Passivo a Descoberto Patrimônio Líquido Negativo – 1ª Parte”. *Boletim Temática Contábil IOB*, nº 13. São Paulo: IOB, 2004, pp. 3-4.

66. MARTINS, Eliseu. “Equivalência patrimonial em investida com patrimônio líquido negativo”. *Caderno de Temática Contábil e Balanços*, nº 28. São Paulo: IOB, 2000, pp. 1-7.

Cabe esclarecer que o procedimento contábil supra não se confunde com aquele a ser adotado na hipótese em que o patrimônio líquido da sociedade investida passa a apresentar valor negativo em momento posterior ao da aquisição do investimento. Neste caso, a sociedade investidora deve registrar normalmente o resultado negativo da equivalência patrimonial, diminuindo o valor do investimento somente até zerar o respectivo saldo contábil. Isso ocorre porque, como o patrimônio líquido passou a apresentar expressão negativa em momento posterior à aquisição do investimento, o valor máximo que o investidor pode perder corresponde ao valor total do investimento realizado. Logo, quando o valor do investimento avaliado pelo MEP atingir o marco zero, pode-se concluir que a sociedade investidora terá reconhecido a perda do valor total do investimento realizado⁶⁷.

Diante do exposto, percebe-se que o artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 fez alusão ao conceito de patrimônio líquido existente na Lei das S/A, sem excepcionar os casos em que a sociedade investida tem patrimônio líquido negativo, tampouco limita o valor do ágio ao preço efetivamente pago. Ao contrário, o legislador tributário incorporou o MEP enquanto um sistema específico de avaliação de investimentos, que não leva em consideração o custo incorrido como única base de valor, por considerar a diferença entre o custo de aquisição e o valor do patrimônio líquido da sociedade investida para efeito de registro de investimentos relevantes em participações societárias.

2.10. Alocação

Antes da Lei nº 12.973/2014, o artigo 20, § 2º, do Decreto-lei nº 1.598/1977, hoje revogado pela Lei nº 12.973, de 2014, determinava que o registro do ágio ou deságio na aquisição do investimento deveria ser acompanhado da indicação de seu fundamento econômico, que poderia ser: a) o valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade; b) a rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados esperados nos exercícios futuros; c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

Por outro lado, as novas regras contábeis, constantes do Pronunciamento Técnico CPC nº 15, requerem que o preço de aquisição seja alocado, primeiro, para ativos e passivos identificáveis, a fim de que apenas a parcela residual do preço seja alocada como ágio de rentabilidade futura (“goodwill”) (item 2, b).

Após a edição da Lei nº 12.973/2014, o artigo 20, I, II e III, do Decreto-lei nº 1.598/1977 passou a prever, de forma expressa, que o preço pago na aquisição

67. DOS SANTOS, Ariovaldo; MACHADO, Itamar Miranda. “Investimentos Avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial – Erro na Contabilização de Dividendos Quando Existem Lucros Não Realizados”. *Revista Contabilidade & Finanças*, nº 39. São Paulo: USP, 2005, p. 13.

de participações societárias será registrado na seguinte ordem: (i) valor do patrimônio líquido na época da aquisição, conforme a legislação societária; (ii) mais-valia ou menos-valia de ativos, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida (ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos) e o valor do patrimônio líquido; e (iii) valor residual, que pode ser ágio por rentabilidade futura (se positivo) ou ganho proveniente de compra vantajosa (se negativo).

Como mencionado supra, a edição de uma nova lei para estabelecer critérios específicos para a alocação do preço pago na aquisição do investimento confirma que, anteriormente, não havia base legal para a imposição dos critérios contábeis.

2.11. Aproveitamento do ágio

Como se sabe, a Lei nº 11.941/2009, ao alterar o artigo 178, § 1º, alínea “c”, da Lei nº 6.404/1976, introduziu a conta de ativo intangível no balanço patrimonial das pessoas jurídicas⁶⁸ no contexto do processo de convergência das regras contábeis brasileiras aos padrões internacionais estabelecidos pelo IASB. Segundo o artigo 179, inciso VI, da Lei nº 6.404/1976, serão classificados no ativo intangível “os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido”.

O item 89 do Pronunciamento Técnico CPC nº 04 estabelece duas abordagens distintas, que variam de acordo com a possibilidade de determinação, ou não, da vida útil do ativo intangível. O ativo intangível com vida útil definida deve ser objeto de amortização contábil (“*amortization approach*”), ao passo que o ativo intangível sem vida útil definida deve ser objeto de teste periódico de recuperabilidade (“*impairment test approach*”). Assim, para o ativo intangível com vida útil definida, as cotas de amortização devem ser apropriadas de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada, em linha com o padrão de consumo ou uso dos benefícios econômicos futuros pela entidade. Diversamente, o ativo intangível sem vida útil definida deverá ser objeto de *teste de recuperabilidade*, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC nº 01 (“Redução ao Valor Recuperável de Ativos”), com periodicidade anual, ou sempre que houver evidências persuasivas de que o ativo intangível não gerará os benefícios econômicos esperados⁶⁹.

68. Artigo 178, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.404/1976.

69. Vide itens 107 e 108 do Pronunciamento Técnico CPC nº 04: “107. Ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. 108. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a entidade deve testar a perda de valor dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, comparando o seu valor recuperável com o seu valor contábil: (a) anualmente; e (b) Sempre que existam indícios de que o ativo intangível pode ter perdido valor”.

Normalmente, o ágio por expectativa de rentabilidade futura não tem prazo de vida útil e, por isso, não pode ser objeto de amortização contábil. Assim, as novas regras contábeis restringiram a amortização contábil do ágio, exatamente em razão da dificuldade de se estabelecer um prazo seguro para tanto. Com isso, o ágio deve permanecer registrado no ativo até que se verifique eventual perda de seu valor recuperável, o que deve ser feito via teste de recuperabilidade⁷⁰. Porém, segundo Miguel Silva, há situações excepcionais em que o ágio por rentabilidade futura pode ter vida útil definida, como ocorre nos casos em que o montante que excede ao valor justo dos ativos líquidos da sociedade adquirida decorre de um direito de concessão, atrelado a efeitos de sinergia que podem aumentar a rentabilidade do empreendimento⁷¹.

Portanto, no atual regime, o ágio é contabilizado como um ativo intangível e, na mais das vezes, não pode mais ser amortizado, submetendo-se ao teste relativo ao valor recuperável de ativos, de acordo com os itens 107 e 108 do Pronunciamento Técnico CPC nº 04. Por isso, o reconhecimento do ágio de rentabilidade futura como despesa dedutível, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, geralmente ocorre via exclusão no e-LALUR e no e-LACS, independentemente da inexistência de despesa reconhecida na escrituração comercial.

Inovando na disciplina jurídica do tema, o *caput* do artigo 22 da Lei nº 12.973/2014 dispõe que a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida com ágio por rentabilidade futura decorrente da aquisição de participação societária entre partes não dependentes, poderá excluir, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, “o saldo do referido ágio existente na contabilidade na data da aquisição da participação societária”, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.

Com tal previsão, o artigo 22 da Lei nº 12.973/2014 deixa claro que eventual teste de recuperabilidade realizado após a aquisição do investimento, mas antes da data de incorporação, fusão ou cisão, não deverá ocasionar efeitos fiscais adversos

70. A respeito do teste de recuperabilidade (“*impairment*”), conferir: BIANCO, João Francisco. “*Impairment: Reflexos Contábeis e Tributários*”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 6º Volume. Coord. Roberto Quiroga Mosquera e Alessandro Broedel Lopes. São Paulo: Dialética, 2015, pp. 273-283; RODRIGUES, Agostinho I. “*Teste de Recuperabilidade do Valor de Ativos – Impairment*”. In: *Prática Tributária nas Empresas – Análise de Questões Tributárias e Contábeis Atuais e Relevantes*. Coord. J. Miguel Silva. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 250-295.

71. SILVA, J. Miguel. “*Ágio ou Deságio nas Reestruturações Societárias*”. In: *Prática Tributária nas Empresas – Análise de Questões Tributárias e Contábeis Atuais e Relevantes*. Coord. J. Miguel Silva. São Paulo: Atlas, 2012, p. 191.

para o contribuinte, uma vez que o valor do ágio a ser amortizado é aquele existente na escrituração contábil no momento da aquisição da participação societária⁷².

O mesmo ocorre em relação à mais-valia de ativos. Como exemplo, ainda que determinado bem seja depreciado pela sociedade adquirida antes da incorporação, fusão ou cisão, o saldo contábil que será integrado ao custo do bem que lhe deu causa, após o evento societário, corresponderá justamente o valor da mais-valia reconhecido no momento da aquisição da participação societária, independentemente da depreciação contábil⁷³.

Trata-se, portanto, de notável alteração legislativa realizada no processo de conversão em lei da Medida Provisória nº 627/2013, cujo artigo 21 havia pretendido restringir o aproveitamento do ágio ao saldo contábil existente no momento do evento de incorporação, fusão ou cisão⁷⁴. Veja-se a redação revogada:

“Art. 21. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida com ágio por rentabilidade futura (*goodwill*) decorrente da aquisição de participação societária entre partes não dependentes, apurado segundo o disposto no inciso III do *caput* do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade na data do evento, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.” (g.n.)

Como se vê, o preceito normativo transcrito pretendia que o valor do ágio passível de amortização para fins fiscais ficasse restrito ao saldo existente na contabilidade na data da incorporação, fusão ou cisão, de modo que eventual teste de recuperabilidade realizado antes do evento societário poderia reduzir o valor passível de aproveitamento pelo contribuinte para fins fiscais.

O Congresso Nacional corretamente repudiou a pretensão do Poder Executivo na conversão da Medida Provisória nº 627/2013, pois, do contrário, o teste de recuperabilidade acarretaria a perda do direito de deduzir um custo que foi efetivamente suportado pelo contribuinte no momento da aquisição do investimento, o que seria incompatível com o conceito de renda e o princípio da capacidade contributiva.

72. LUZ, Victor Lyra Guimarães. *Fusões e Aquisições: Regime Jurídico do Ágio*. São Paulo: Almedina, 2019, p. 113.

73. ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti; ALMEIDA, Rafael Jachelli. *Regulamentação Fiscal das Normas Contábeis do IFRS e CPC: Lei nº 12.973/14*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 163.

74. SILVEIRA, Ricardo Maito; SILVEIRA, Rodrigo Maito. “Evolução Histórica do Benefício Fiscal de Amortização do Ágio na Aquisição de Participações Societárias e a Nova Regulamentação Introduzida pela Lei nº 12.973/2014”. In: *Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Vol. IV*. Coord. Sérgio André Rocha. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 465.

Além disso, sob o enfoque do princípio da igualdade, o artigo 21 da Medida Provisória nº 627/2013 acabaria por privilegiar a pessoa jurídica que decidiu realizar de forma mais rápida a operação societária que acarreta a confusão patrimonial⁷⁵, sem qualquer justificativa plausível para o tratamento tributário diferenciado.

Superada a questão relativa ao valor do ágio, cabe enfrentar a discussão relacionada ao caráter facultativo da sua amortização fiscal. O artigo 22 da Lei nº 12.973/2014 prevê que o contribuinte “*poderá excluir* para fins de apuração do lucro real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração” (g.n.).

Sabe-se que, em casos de modais epistêmicos, a diferença entre “poder” e “dever” poder ser sutil. Como exemplo, imagine-se a frase “aquilo lá no céu deve ser um avião”, em comparação com a frase “aquilo lá no céu pode ser um avião”. Em tal situação, o indivíduo, com base em seu conhecimento da realidade, conclui que o objeto identificado no céu “deve ser um avião” ou “pode ser um avião”, a depender das evidências concretas. Nessa hipótese, a única diferença entre as duas frases está relacionada ao grau de base epistêmica e de fonte de ordenação estereotípica que o indivíduo possui para estabelecer a relação entre o objeto no céu e o avião. Entretanto, a situação é diferente quando se trata de um modal deontico, no qual o verbo “dever” designa uma necessidade ou obrigação de cumprimento da lei, ao passo que o verbo “poder” indica uma possibilidade ou faculdade⁷⁶.

A partir da distinção acima, percebe-se que o verbo “poderá” foi utilizado no artigo 22 da Lei nº 12.973/2014 como uma faculdade outorgada ao contribuinte, o que é confirmado pelo limite de 1/60 (um sessenta avos), “no máximo”, para cada período de apuração. A existência de um limite máximo para a amortização fiscal do ágio corrobora que o contribuinte pode excluir um montante inferior ao valor máximo permitido.

Portanto, a distinção entre “poder” e “dever” há de ser considerada na interpretação do artigo 22 da Lei nº 12.973/2014, tal como ocorre em diversos outros casos estabelecidos na legislação tributária. O exemplo clássico reside na regra de depreciação prevista no artigo 57 da Lei nº 4.506/1964, segundo a qual “*poderá ser* computada como custo ou encargo, em cada exercício, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal” (g.n.). Ao tratar da imputação temporal dos encargos de depreciação, o Parecer Normativo CST n. 79/1976, item 2, conclui que

75. AMARO, Luciano; TAKATA, Marcos Shiguo. “Amortização Fiscal de Ágio já Amortizado contabilmente”. *Revista Dialética de Direito Tributário*, nº 243. São Paulo: Dialética, 2015, p. 87.

76. RESENDE, Maurício. “Algumas diferenças semânticas entre *dever* e *poder*”. *Revista Versalete*. Vol. 3. Nº 5. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2015, pp. 36-49.

“a depreciação dos bens do ativo é uma faculdade, não uma obrigação, conforme se depreende da análise literal dos dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda que tratam da matéria (...). Essa afirmativa é fundada nos vocábulos ‘poderá’ e ‘poderão’, insertos no início dos artigos citados. Assim, não há obrigatoriedade de se efetuar a depreciação em todos os exercícios financeiros de atividade da empresa. A legislação tributária fixa percentuais máximos e períodos mínimos de depreciação, não proibindo a empresa de apropriar quotas inferiores às permitidas, ou mesmo deixar de depreciar”. Idêntico raciocínio se aplica à amortização fiscal do ágio, cujo pressuposto de imputação temporal é até menos objetivo do que aquele aplicável aos encargos de depreciação, que seguem o desgaste ou a perda de utilidade do bem.

De todo modo, isso não significa que o contribuinte pode manipular abusivamente a amortização fiscal do ágio. Na realidade, ainda que o valor do ágio seja residual na Lei nº 12.973/2014 e não esteja diretamente atrelado à expectativa de rentabilidade futura, a alteração do coeficiente de amortização deve ser justificada com base nas circunstâncias particulares da participação societária adquirida.

Na Solução de Consulta COSIT nº 223, de 26.06.2019, a Administração Tributária manifestou seu entendimento no sentido de que a amortização do ágio por rentabilidade futura, via exclusões do lucro real e da base de cálculo da CSLL, deve ser feita de modo ininterrupto e em coeficiente fixo ao longo do tempo, observado o limite máximo de 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do período de apuração. Na visão da COSIT, a fração de amortização a ser utilizada pelo contribuinte deve ser fixada no primeiro período de apuração após a operação societária que culminou com a absorção do patrimônio da sociedade investida, não podendo ser modificada posteriormente. Como dito supra, não se concorda integralmente com tal interpretação, pois a noção de faculdade pressupõe que o coeficiente de amortização utilizado pelo contribuinte pode ser ajustado em face das circunstâncias de seu caso concreto, desde que não haja abuso.

A impossibilidade de manipulação abusiva decorre do fato de que o exercício de tal faculdade por parte do contribuinte não é ilimitado. O individualismo jurídico, manifestado no brocado “*qui jure suo utitur neminem laedi*”, segundo o qual “quem usa de seu direito a ninguém prejudica”, paulatinamente perdeu espaço para uma concepção relativista dos direitos, consagrada na obra de Andreas von Tuhr, para quem o exercício dos direitos encontra limite nos direitos alheios que se lhe opõem⁷⁷. É justamente por isso que, segundo Orlando Gomes, “o exercício dos direitos deve ser normal. O princípio de que cada qual pode usar de seu direito

77. VON TUHR, Andreas. *Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts*, Volume III. Berlin: Duncker & Humblot, 1918, p. 559, apud MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Tomo 6. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000, p. 123.

como lhe convém é inaceitável. Quem usa, de modo anormal, de seu direito comete abuso de direito⁷⁸. Sendo assim, tal como qualquer outro direito consagrado pelo ordenamento jurídico pátrio, a faculdade relativa à amortização fiscal do ágio não pode ser exercida de forma abusiva pelo contribuinte.

No entanto, cabe pontar que o abuso de direito somente restará caracterizado na hipótese em que o titular de um direito subjetivo, de forma dolosa, ultrapassar os limites impostos ao seu exercício, com o fim de prejudicar um terceiro⁷⁹. O mero ajuste no coeficiente de amortização fiscal do ágio não caracteriza abuso de direito, desde que não haja intenção do contribuinte de lesar o Erário. Se o contribuinte apenas regula a amortização fiscal do ágio para adequar as suas bases tributárias, ainda que com o objetivo de reduzir a sua carga tributária e, consequentemente, aumentar a sua margem de lucro, não haverá abuso de direito. É até possível que, com a alteração do coeficiente de amortização, o Estado tenha a sua arrecadação impactada em termos temporais⁸⁰. Porém, se o contribuinte não foi movido pelo desejo de prejudicar o Estado, mas, sim, pelo propósito de aumentar o seu ganho econômico, reduzindo o ônus tributário que recai sobre a sua atividade econômica, não há que se falar em abuso de direito. Isso é assim porque o traço característico do abuso de direito reside no exercício de um direito de forma imoderada, excessiva e sem utilidade para o seu titular (i.e. sem um objetivo sério e legítimo), apenas com a intenção de prejudicar ou causar um dano a um terceiro⁸¹.

Note-se que a mera existência de um prejuízo ao Fisco não é suficiente para caracterizar o abuso de direito. Isso porque, se assim o fosse, nenhum credor poderia exigir o pagamento de uma dívida de um devedor em má situação financeira, pois isso certamente prejudicaria a outra parte da relação jurídica⁸². O abuso de direito somente existirá se a dívida em questão for cobrada mediante o uso de meios vexatórios.

Por fim, é oportuno frisar que, em qualquer caso, o contribuinte deve observar o limite máximo de 1/60 avos para cada mês do período de apuração, não sendo possível acumular os valores não utilizados nos anos-calendário anteriores. Isso não significa, porém, que o contribuinte que efetuou o recolhimento das

78. GOMES, Orlando. *Introdução ao Direito Civil*. 19ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 118.

79. SCHOUERI, Luís Eduardo. *Distribuição Disfarçada de Lucros*. São Paulo: Dialética, 1996, pp. 141-146.

80. A redução do coeficiente de amortização aparenta favorecer o fisco, mas pode prejudicá-lo se a dedução posterior afetar as regras de formação e compensação de prejuízos fiscais.

81. ATIENZA, Manuel; MANERO, Juan Ruiz. *Ilícitos atípicos: sobre abuso de direito, fraude à lei e desvio de poder*. São Paulo: Marcial Pons, 2014, pp. 35-50.

82. SCHOUERI, Luís Eduardo. *Distribuição Disfarçada de Lucros*. São Paulo: Dialética, 1996, p. 150.

antecipações mensais de IRPJ e CSLL com base na receita bruta não possa deduzir o limite anual de amortização do ágio por ocasião do cálculo do ajuste anual. Daí não se concordar com o entendimento que prevaleceu no acórdão nº 1401-003.043 (CARF), de 11.12.2018, no qual se afirmou a necessidade de observância do limite mensal de 1/60 avos para a amortização fiscal do ágio, mantendo-se a glosa da dedução supostamente realizada a maior no cálculo do ajuste anual, ainda que o limite anual tivesse sido devidamente respeitado pelo contribuinte⁸³.

2.12. Aproveitamento da mais ou menos-valia de ativos

O artigo 20 da Lei nº 12.973/2014 regulamentou o tratamento fiscal que deve ser aplicado ao saldo de mais-valia após a operação de incorporação, fusão e cisão, nos seguintes termos:

“Art. 20. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo existente na contabilidade, na data da aquisição da participação societária, referente à mais-valia de que trata o inciso II do *caput* do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, decorrente da aquisição de participação societária entre partes não dependentes, *poderá ser considerado como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu causa*, para efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do cômputo da depreciação, amortização ou exaustão” (g.n.).

A redação do texto legal é imperfeita, pois se limita a estabelecer que o saldo da mais-valia existente na contabilidade deve ser computado ao custo do bem ou direito que lhe deu causa, seja para efeito de determinação de ganho ou perda de capital, seja para fins de cômputo da depreciação, amortização ou exaustão.

Com isso, o texto legal deixa de considerar, por exemplo, a mais-valia relativa ao estoque, uma vez que o resultado proveniente da alienação de bens do estoque constitui receita bruta⁸⁴, que não se confunde com o ganho de capital⁸⁵. Além disso, o estoque é baixado no momento das vendas realizadas pela pessoa jurídica, sem relação direta com a depreciação, amortização ou exaustão das aplicações de capital.

De qualquer forma, deixando de lado essa imperfeição linguística, o fato é que, após o evento de incorporação, fusão ou cisão, a mais-valia inicialmente reconhecida pela sociedade investidora no momento da aquisição da participação societária passa a integrar o custo do ativo absorvido no evento societário, tanto para

83. Confira-se o seguinte trecho da ementa da decisão: “A legislação é clara que a amortização do ágio somente pode ser realizada à razão de 1/60. Não existindo qualquer fundamentação no laudo que justifique a alteração dos limites, mesmo que dentro do mesmo ano calendário, deve ser observada a legislação devendo ser o ágio recomposto para a utilização em períodos futuros”.

84. Artigo 12, inciso I, do Decreto-lei nº 1.598/1977.

85. Artigo 31 do Decreto-lei nº 1.598/1977.

fins contábeis, quanto para fins fiscais. Assim, tanto a mais-valia atribuída aos bens ou direitos sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão, quanto a mais-valia dos estoques devem ser computadas como custo do ativo correspondente, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, sob pena de violação ao conceito jurídico de renda.

Note-se que, após o evento de incorporação, fusão ou cisão, o saldo de mais-valia existente na contabilidade deve ser computado ao custo do bem ou direito que lhe deu causa, para efeito de cálculo dos encargos de depreciação, amortização ou exaustão. Assim, a dedução fiscal do valor da mais-valia passa a depender do regime tributário aplicável ao respectivo bem. Como exemplo, caso a mais-valia seja atribuída a bem não depreciable, como um terreno⁸⁶ ou uma obra de arte utilizada para decoração⁸⁷, o valor da mais-valia somente será dedutível no momento da alienação ou baixa.

Outro exemplo envolve a mais-valia atribuída a um bem objeto de arrendamento mercantil financeiro, que passou a ser contabilizado como ativo imobilizado da pessoa jurídica arrendatária, apesar da inexistência de título jurídico de propriedade. Essa forma de contabilização deriva do artigo 179, inciso IV, da Lei nº 6.404/1976, com a redação dada pela Lei nº 11.638/2007, segundo qual devem ser registrados, no ativo imobilizado, os direitos “decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens”. Ocorre que o legislador tributário, ao disciplinar o tratamento aplicável às operações de arrendamento mercantil financeiro, decidiu observar a titularidade jurídica do bem, neutralizando os efeitos das novas regras contábeis. Por isso, a pessoa jurídica arrendatária não poderá deduzir, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, as despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem objeto de arrendamento mercantil financeiro⁸⁸⁻⁸⁹. Consequentemente, a parcela da mais-valia atribuída ao bem arrendado, além de reduzir o valor contábil do ágio, não poderá ser deduzida para fins fiscais, mesmo após o evento de incorporação, fusão ou cisão⁹⁰.

86. Artigo 57, § 10, alínea “a”, da Lei nº 4.506/1964. Vale mencionar que, no acórdão nº 108-05.888, de 20.10.1999, a 8ª Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes admitiu a depreciação de terreno utilizado como aterro para lançamento de resíduos industriais, pelo prazo de 50 anos estabelecido na escritura da autoridade sanitária.

87. Artigo 57, § 10, alínea “c”, da Lei nº 4.506/1964.

88. Artigo 13, inciso VIII, da Lei nº 9.249/1995.

89. Segundo o artigo 47 da Lei nº 12.973/2014, a pessoa jurídica arrendatária poderá deduzir, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, as contraprestações pagas ou creditadas por força de contrato de arrendamento mercantil, referentes a bens móveis ou imóveis intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços, inclusive as despesas financeiras nelas consideradas.

90. Para uma análise mais detida do tema, vide: TONANNI, Fernando; MARRARA, Bruna. “Ágio na Lei n. 12.973/2014: Controle de Legalidade e Distanciamentos entre Ágio

No caso de bens ou direitos sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão, a dedução da mais-valia apenas será admitida caso os referidos ativos estejam intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços, nos termos do artigo 13, inciso III, da Lei nº 9.249/1995.

A exigência de que os bens ou direitos estejam “intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços”, embora constante da regra geral aplicável às incursões de capital, pode suscitar determinadas dúvidas no âmbito das operações de combinação de negócios. Isso porque, por força do Pronunciamento Técnico CPC nº 15, a pessoa jurídica adquirente deverá alocar parte do preço de aquisição aos ativos tangíveis e intangíveis adquiridos na operação, independentemente da possibilidade concreta de utilização, ou não, de tais bens ou direitos na sua atividade econômica.

Apenas para fins de ilustração, é possível que uma pessoa jurídica seja obrigada a alocar uma parcela do custo de aquisição a um bem que não será efetivamente utilizado na produção ou comercialização de bens ou serviços, como um avião executivo utilizado no transporte de seus diretores. Nessa situação, pela regra geral do artigo 13, inciso III, da Lei nº 9.249/1995, o bem não seria passível de depreciação, por não estar intrinsecamente relacionado com a produção ou a comercialização de bens ou serviços. Porém, no contexto da operação de combinação de negócios, a pessoa jurídica deve atribuir uma parcela do preço de aquisição à mais-valia do referido bem, ainda que saiba, de antemão, da ausência de vinculação entre o jato executivo e a atividade de produção e comercialização de bens ou serviços. Em tal situação, a mais-valia deverá ser considerada como uma parcela integrante do custo de aquisição da aeronave, para efeito de determinação de eventual ganho ou perda de capital no momento de sua baixa.

Aliás, é justamente por isso que o § 2º do artigo 20 da Lei nº 12.973/2014 apenas faz remissão ao artigo 13, inciso III, da Lei nº 9.249/1995 para tratar da dedutibilidade das despesas de depreciação, amortização ou exaustão, sem fazer qualquer alusão ao custo do ativo para efeito de apuração de eventual ganho ou perda de capital. A forma utilizada pelo legislador na remissão legal confirma que essa restrição não impede a consideração da mais-valia como parcela integrante do custo de aquisição do bem ou direito, para efeito de determinação de eventual ganho ou perda de capital.

Cabe mencionar que a expressão “intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços”, utilizada no artigo 13, inciso III, da Lei nº 9.249/1995, não deve ser interpretada de forma rígida e inflexível. Como aponta Ricardo Mariz de Oliveira, para que essa regra seja compatível com o

Contábil e o Novo Regime Legal”. In: *Impactos Tributários Decorrentes da Adoção do IFRS no Brasil: Uma Década de Debates*. Coord. Giancarlo Chamma Matarazzo e Luiz Felipe Centeno Ferraz. São Paulo: Blucher, 2019, pp. 30-32.

ordenamento jurídico, há de se entender que o bem ou o direito deve ser empregado no exercício da atividade econômica da pessoa jurídica, mas não necessariamente na produção ou comercialização de bens ou serviços. Do contrário, os bens utilizados no escritório administrativo da pessoa jurídica, ou em outros setores que não envolvam a produção ou a comercialização de bens ou serviços, não gerariam custos e despesas dedutíveis para fins fiscais, o que desvirtuaria a base de cálculo do imposto de renda⁹¹.

No mais, lembre-se que o artigo 25, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF nº 11/1996 traz uma lista bens ou direitos intrinsecamente relacionados à produção ou comercialização de bens ou serviços, o que pode auxiliar o intérprete na solução de casos concretos, mas com a ressalva de que o bem ou direito pode estar apenas *indiretamente* relacionado com a produção ou a comercialização de bens ou serviços, de modo a alcançar itens empregados em outros setores da empresa⁹².

Seguindo adiante, cabe mencionar que a necessidade de junção da mais-valia com o custo de aquisição do bem ou direito, por meio do evento de incorporação, fusão ou cisão, pode dar azo a dificuldades operacionais e societárias relevantes nos casos em que a sociedade adquirida detém investimentos em outras sociedades, cujos ativos líquidos também foram objeto de avaliação no laudo técnico relativo à combinação de negócios⁹³. Em tal situação, pela sistemática prevista no artigo 20 da Lei nº 12.973/2014, o aproveitamento fiscal da mais-valia atribuída à sociedade controlada indireta dependeria da realização de operação societária que acarretasse a junção da mais-valia com o custo de aquisição do bem ou direito que lhe deu causa, o que pode ser absolutamente inviável, além de indesejável pelas partes em certas circunstâncias.

Conquanto seja claro o racional que orientou a Lei nº 12.973/2014, não parece razoável exigir que a pessoa jurídica adquirente incorpore, além da sociedade adquirida, todas as demais controladas indiretas que detenham ativos a valor justo por ocasião da combinação de negócios. Para evitar tal inconveniente, o ideal seria aplicar, para tais situações, a regra prevista no § 1º do artigo 20 da Lei nº 12.973/2014, que permite a dedução da mais-valia em quotas fixas mensais e no

91. OLIVEIRA, Ricardo Mariz. *Fundamentos do Imposto de Renda*. São Paulo: Quartier Latin, 2008, pp. 413-417.

92. OLIVEIRA, Ricardo Mariz. *Fundamentos do Imposto de Renda*. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 724.

93. NATALE, Marcelo; QUERQUILLI, Alexandre Garcia. "Aspectos Relevantes do Desdobramento do Custo de Aquisição de Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido". In: *Impactos Tributários Decorrentes da Adoção do IFRS no Brasil: Uma Década de Debates*. Coord. Giancarlo Chamma Matarazzo e Luiz Felipe Centeno Ferraz. São Paulo: Blucher, 2019, p. 59.

prazo mínimo de 5 (cinco) anos, nos casos em que o bem ou direito que deu causa a mais-valia não houver sido transferido para o patrimônio da pessoa jurídica sucessora em virtude de cisão parcial⁹⁴.

De fato, segundo o § 1º do artigo 20 da Lei nº 12.973/2014, se o bem ou direito que deu causa a mais-valia não houver sido transferido para o patrimônio da pessoa jurídica sucessora em virtude de cisão parcial, esta poderá, para efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, deduzir a referida importância em quotas fixas mensais e no prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da data do evento. Trata-se, assim, de uma regra de imputação temporal do custo da mais-valia ao resultado da pessoa jurídica adquirente, que poderá deduzi-lo a uma taxa de até 20% ao ano, nos casos em que o bem ou direito não integrar o acervo líquido cindido.

Sem prejuízos das considerações precedentes, é conveniente apontar que, embora a contabilidade possa reconhecer a mais-valia de sociedades controladas indiretas em operações de combinação de negócios, o artigo 20, inciso II, do Decreto-lei nº 1.598/1977 define a mais ou menos-valia como a “diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida”. Sendo assim, sob o enfoque do direito tributário, apenas os ativos e passivos da sociedade investida deveriam ser objeto de alocação de mais ou menos-valia. Logo, para evitar futuros inconvenientes, o ideal é que o laudo de avaliação a ser preparado para fins fiscais considere apenas a mais ou menos-valia de ativos e passivos da sociedade adquirida, de modo que eventual mais-valia atribuída a um bem ou direito da sociedade controlada indireta passaria a compor o valor residual do ágio.

E nem se alegue que o termo “investida”, utilizado no texto legal, deve ser interpretado de forma ampla, para abranger tanto as sociedades controladas diretas, quanto as sociedades controladas indiretas. Isso porque, embora o direito societário alcance o controle societário exercido de forma indireta, por meio de outras sociedades, o artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 trata especificamente do investimento avaliado pelo MEP, no qual os resultados das controladas indiretas estão refletidos no patrimônio líquido da controlada direta. Dessa forma, como não há aplicação “*per saltum*” do MEP, é evidente que apenas os ativos líquidos da sociedade investida devem ser avaliados.

De resto, tal como ocorre em relação ao ágio, a pessoa jurídica adquirente não poderá aproveitar a mais-valia quando: (i) o laudo de avaliação não for elaborado e tempestivamente protocolado ou registrado na forma da lei; (ii) os valores que compõem o saldo da mais-valia não puderem ser identificados em decorrência da não observância do controle em subcontas distintas do ágio e da mais ou

94. Vide uma análise mais detida do § 1º do artigo 20 da Lei nº 12.973/2014 no tópico 3.13 abaixo.

menos-valia; e (iii) o laudo de avaliação for desconsiderado, em virtude da existência de vícios ou incorreções de caráter relevante⁹⁵.

Vale mencionar que a exigência do laudo de avaliação, para fins de aproveitamento da mais-valia, não se aplica às participações societárias adquiridas até 31 de dezembro de 2013, para os optantes pelo regime de aplicação antecipada da lei⁹⁶, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes⁹⁷.

Trata-se, assim, de regra de direito intertemporal que está em linha com a entrada em vigor do regime da Lei nº 12.973/2014, pois, no caso de participações societárias adquiridas antes da nova lei, o prazo de 13 (treze) meses para registro do laudo de avaliação poderia ter expirado antes mesmo da criação da exigência legal, o que tornaria a apresentação desse documento uma obrigação impossível.

Seja como for, a dispensa de laudo de avaliação não afasta a necessidade de o contribuinte manter documentação hábil idônea e suficiente para fazer prova da mais-valia de ativos. Isso porque a exigência de prova para suportar os lançamentos contábeis não é novidade e o artigo 20, § 3º, do Decreto-lei nº 1.598/1977, em sua redação original, já exigia que os fundamentos econômicos do ágio ou do deságio apurados na aquisição de participação societária estivessem lastreados em demonstração que o contribuinte deveria arquivar como comprovante da escrituração.

A diferença é que, no regime introduzido pela Lei nº 12.973/2014, a demonstração a ser feita pelo contribuinte deixou de focar no ágio ou no deságio. Com efeito, com a edição da nova lei, o contribuinte deve fazer prova da mais ou menos-valia de ativos. Eventual valor residual, quando existente, tem a natureza de ágio ou ganho por compra vantajosa, na forma do artigo 20, inciso III e § 5º, do Decreto-lei nº 1.598/1977, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.973/2014.

Para comprovar a mais-valia de ativos, o contribuinte poderá utilizar quaisquer meios de prova admitidos pelo Direito, como o próprio laudo de alocação do preço de compra exigido pelas novas regras contábeis.

Por fim, note-se que o mesmo tratamento tributário se aplica, com as devidas adaptações, à menos-valia de ativos. Segundo o artigo 21 da Lei nº 12.973/2014, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo existente na contabilidade, na data da aquisição da participação societária, referente à menos-valia, deverá ser considerado como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu causa, para efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do cômputo da depreciação, amortização ou exaustão.

95. Os requisitos relativos ao laudo de avaliação estão avaliados em capítulo específico.

96. A opção pelo regime de aplicação antecipada está prevista no artigo 75 da Lei nº 12.973/2014.

97. Artigo 20, § 5º, da Lei nº 12.973/2014.

2.13. A mais ou menos-valia e os ativos não transferidos nos casos de incorporação, fusão e cisão

Como visto supra, segundo o artigo 20, § 1º, da Lei nº 12.973/2014, se o bem ou direito que deu causa a mais-valia não houver sido transferido para o patrimônio da pessoa jurídica sucessora em virtude de cisão parcial, esta poderá, para efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, deduzir a referida importância em quotas fixas mensais e no prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da data do evento. Veja-se:

“Art. 20. (...)

§ 1º. Se o bem ou direito que deu causa ao valor de que trata o caput não houver sido transferido, na hipótese de *cisão*, para o patrimônio da sucessora, esta poderá, para efeitos de apuração do lucro real, deduzir a referida importância em quotas fixas mensais e no prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da data do evento.”

Como se vê, o dispositivo legal supra apenas disciplina o tratamento fiscal a ser aplicado à mais-valia de ativo não transferido em virtude de cisão parcial, deixando de tratar dos bens que, eventualmente, já tenham sido baixados contabilmente ou alienados pela sociedade investida antes da incorporação, fusão ou cisão (integral).

Diante da lacuna, a Administração Tributária, por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, determinou que a sociedade adquirente não poderá excluir o valor da mais-valia do lucro real e da base de cálculo da CSLL, caso o bem já tenha sido alienado ou baixado na data do evento de incorporação, fusão ou cisão. É o que se extrai do artigo 186, § 4º, do referido ato normativo:

“Art. 186. Para efeitos do disposto no inciso I do art. 185:

(...)

§ 4º O valor da mais-valia registrado contabilmente na data de aquisição da participação societária não poderá ser excluído na apuração do lucro real e do resultado ajustado caso o bem já tenha sido alienado ou baixado na data do evento de incorporação, fusão ou cisão.”

Ocorre que o artigo 186, § 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 é ilegal, pois, além de não encontrar suporte na Lei nº 12.973/2014, ainda viola o conceito de renda e o princípio da renda líquida, que devem orientar a interpretação das regras jurídicas que disciplinam o tratamento tributário do ágio e da mais-valia de ativos nas aquisições de participações societárias.

O entendimento da Administração Tributária parece estar baseado em uma interpretação “*a contrario sensu*” do artigo 20, § 1º, da Lei nº 12.973/2014, segundo o qual a mais valia deverá compor, após o evento de confusão patrimonial, o custo de

aquisição do bem ou direito que deu causa ao seu registro. Inversamente, se não houver a transmissão do referido bem ou direito para a sociedade adquirente, não será possível apropriar a mais-valia gerada no momento da aquisição do investimento.

A utilização do argumento “*a contrario sensu*” no caso em pauta deve ser vista com cautela, pois não se está diante de um “silêncio eloquente”, no qual a falta de regulamentação expressa, pelo legislador, tem o significado de uma previsão de consequências normativas antagônicas àquelas estipuladas pela norma jurídica derivada da interpretação do dispositivo legal em exame⁹⁸. Dito de outra forma, somente seria possível invocar o argumento “*a contrario sensu*” se a Lei nº 12.973/2014, ao tratar exclusivamente dos bens ou direitos não transferidos para a pessoa jurídica adquirente em virtude de cisão parcial, tivesse pretendido impedir a dedução da mais-valia de ativos não transferidos na incorporação, fusão ou cisão (integral). Ora, não parece ser esse o caso, tendo em vista que, conforme enfatizado no capítulo 1 desta obra, o ágio pago na aquisição do investimento deve ser dedutível para fins fiscais, sob pena de tributação do patrimônio da pessoa jurídica, em violação às regras constitucionais de discriminação de competências e aos princípios da capacidade contributiva e da renda líquida.

Além disso, no caso do artigo 20, § 1º, da Lei nº 12.973/2014, a relação entre a hipótese normativa (não transferência do bem ou direito que deu causa a mais-valia para a pessoa jurídica sucessora) e a consequência jurídica (dedução da mais-valia em quotas fixas mensais e no prazo mínimo de 5 anos) constitui uma implicação extensiva, o que torna o argumento “*a contrario sensu*” um verdadeiro sofisma. Ou seja, valendo-se apenas do argumento “*a contrario sensu*”, jamais será possível dizer que a não transferência do bem ou direito que deu causa a mais-valia de ativos é a única hipótese que autoriza a sua dedução em quotas fixas mensais, no prazo mínimo de 5 anos. Assim, para a aplicação do argumento “*a contrario sensu*”, seria preciso estar diante de uma implicação intensiva ou de uma implicação recíproca entre a hipótese normativa e a sua consequência jurídica, o que não se verifica no caso em tela⁹⁹.

Outrossim, a restrição prevista no artigo 186, § 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 é assistemática no contexto da Lei nº 12.973/2014, cujo artigo 20 admite a dedução do saldo de mais-valia existente na contabilidade na data da aquisição da participação societária¹⁰⁰. Ora, se o marco temporal para a mensuração

98. BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. *Teoria do Direito e Decisão Racional: Temas de Teoria da Argumentação Jurídica*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 374.

99. BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. *Teoria do Direito e Decisão Racional: Temas de Teoria da Argumentação Jurídica*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 374-376.

100. BENTO, Sergio. “Tratamento Tributário do Ágio”. In: *Lei 12.973/14 – Novo Marco Tributário: Padrões Internacionais de Contabilidade*. Coord. Marcelo Lima Vieira et al. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 135.

do valor da mais-valia (e do próprio ágio) é a data de aquisição da participação societária, é porque os eventos subsequentes de realização contábil via depreciação, amortização, exaustão ou baixa são irrelevantes para fins fiscais. E nem poderia ser diferente, por se tratar de um custo de aquisição efetivamente suportado pelo contribuinte no momento da aquisição do investimento, isto é, no instante em que o direito de propriedade sobre as quotas ou ações da sociedade investida se incorpora ao patrimônio do contribuinte.

Pela mesma razão, o artigo 186, § 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 também é incongruente com o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei nº 12.973/2014, que admite a dedução, no prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da mais-valia referente aos bens que não foram transferidos para a sociedade adquirente em virtude de cisão parcial¹⁰¹. A bem de ver, não há qualquer justificativa plausível para a diferenciação entre a mais-valia de bens que não foram transferidos em virtude de cisão parcial e a mais-valia de bens que não foram transferidos em razão de sua realização na sociedade investida, antes da incorporação, fusão ou cisão, pois ambas parcelas compõem o custo de aquisição suportado pela sociedade adquirente, cuja dedução deve ser admitida para a apuração do acréscimo patrimonial passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL.

A Receita Federal do Brasil, na questão 75 do seu “Perguntas e Respostas”¹⁰², abordou o tratamento tributário a ser aplicado aos bens integralmente depreciados, amortizados ou exauridos no evento societário de incorporação, fusão ou cisão, reconhecendo a possibilidade de sua exclusão do lucro real e da base de cálculo da CSLL no momento da alienação ou baixa. Veja-se:

“Avaliação do Investimento – Coligadas e Controladas

075. Em que prazo poderá ser excluído o saldo existente na contabilidade na data da aquisição do investimento, nos casos de bens 100% depreciados/amortizados/exauridos à data da incorporação?

O valor da mais valia poderá ser excluído do lucro líquido para apuração do lucro real quando o bem for baixado ou alienado.”

Como se vê, essa questão trata dos bens que foram efetivamente transferidos para a pessoa jurídica adquirente no evento societário de incorporação, fusão ou cisão, mas que já estão totalmente depreciados, amortizados ou exauridos.

101. BENTO, Sergio. “Tratamento Tributário do Ágio”. In: *Lei 12.973/14 – Novo Marco Tributário: Padrões Internacionais de Contabilidade*. Coord. Marcelo Lima Vieira et al. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 135.

102. <http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/erguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2019-arquivos/perguntas-e-respostas-pj-2019-arquivo-unico.pdf>

Trata-se, assim, de hipótese distinta daquela em que os bens foram alienados ou baixados pela sociedade adquirida, antes do evento societário.

Seja como for, fato é que o artigo 186, § 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 é ilegal, pois não se pode admitir que a Administração Tributária, por meio de ato normativo infralegal, restrinja o direito à dedução de uma parcela de um custo de aquisição legitimamente suportado pelo contribuinte, cuja alocação à mais-valia de ativos ocorre apenas para fins de determinação do momento de sua imputação temporal às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Tecnicamente, o ágio constitui uma parcela do custo de aquisição incorrido pela pessoa jurídica adquirente de uma participação societária, independentemente da alocação atualmente exigida pela Lei nº 12.973/2014, em linha com o Pronunciamento Técnico CPC nº 15. Daí não ser possível restringir o direito à dedução de uma parcela do custo de aquisição do investimento, com base no simples argumento de que o bem que deu origem à mais-valia não foi transferido para a pessoa jurídica adquirente por incorporação, fusão ou cisão. O contribuinte efetivamente suportou um custo de aquisição, que dever ser deduzido para fins fiscais.

Superado esse ponto, a segunda questão a ser enfrentada diz respeito ao momento em que esta mais-valia, que não pôde ser alocada a um bem específico no evento societário, passa a ser dedutível do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

Em rigor, essa mais-valia deveria ser considerada dedutível no momento do evento de fusão, incorporação ou cisão de sociedades. Isso porque a mais-valia é uma parcela do custo incorrido na aquisição da participação societária que foi extinta, total ou parcialmente, no evento societário, que constitui o evento crítico de realização. O legislador tributário, ao prever que a mais-valia será dedutível segundo a depreciação, amortização ou exaustão do bem ou direito que lhe deu causa, apenas diferiu a dedução de um custo de aquisição que seria dedutível no momento do evento societário.

Essa interpretação é reforçada pelo fato de que a sociedade investidora adquiriu ações ou quotas que representam a sua participação no capital social da sociedade investida. Não houve a aquisição de bens ou direitos que integram o patrimônio da sociedade investida. Dessa forma, embora a alocação contábil do custo de aquisição aos ativos adquiridos e passivos assumidos tenha sido absorvida, com modificações, pela Lei nº 12.973/2014, é de se reconhecer que, na impossibilidade de cômputo da mais-valia ao custo de bens ou direitos específicos por ocasião do evento societário de confusão patrimonial, essa parcela do custo de aquisição deveria ser considerada dedutível do lucro real e da base de cálculo da CSLL no momento da incorporação, fusão ou cisão.

A despeito da posição técnica supra ser a mais correta, também seria possível, de forma conservadora, aplicar o mesmo critério previsto no artigo 20, § 1º, da Lei nº 12.973/2014 para os bens ou direitos que não foram transferidos para pessoa

jurídica sucessora em virtude de cisão parcial, hipótese em que a mais-valia poderá ser deduzida do lucro real e da base de cálculo da CSLL em quotas fixas mensais e no prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da data do evento societário.

Note-se que o uso de analogia, em tal hipótese, não encontra óbice no artigo 108, § 1º, do CTN, segundo o qual “o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.” Obviamente, não se trata aqui de emprego de analogia para a exigência de tributo, mas, sim, para a determinação do critério temporal de apropriação de um custo dedutível para fins fiscais.

O emprego de analogia no direito tributário depende da observância de determinadas etapas, que podem ser assim segregadas:

1. A identificação da existência de lacuna;
2. O princípio da igualdade deve exigir a mesma solução para ambos os casos, sem que haja justificativa para o tratamento diferenciado;
3. A colmatação da lacuna deve observar os limites impostos à atividade integradora do direito positivo.

Obviamente, essas etapas são segregadas apenas para fins didáticos, pois o processo mental de interpretação é inalcançável e irredutível a etapas estanques.

Em primeiro lugar, é preciso distinguir a “lacuna” do “vazio jurídico” ou do “silêncio eloquente”, pois apenas a primeira deve ser objeto de integração.

A “lacuna” consiste na ausência de norma jurídica a ser aplicada a determinado predicado fático, em virtude da incompletude do ordenamento jurídico. Diferentemente, o “vazio jurídico”, também chamado de “silêncio eloquente”, consiste na ausência de norma jurídica por opção do legislador. Trata-se, assim, de um predicado fático intencionalmente não apreendido pela lei¹⁰³. Para verificar se há “lacuna” ou “vazio jurídico”, não há uma solução apriorística, cabendo ao intérprete realizar uma valoração crítica da lei, segundo a pauta de sua própria teleologia¹⁰⁴.

No caso em questão, há uma efetiva “lacuna” no tratamento da mais-valia relativa ao bem ou direito não transferido para a pessoa jurídica adquirente no evento societário, pois a Lei nº 12.973/2014 aspira uma regulamentação completa das consequências oriundas das novas regras contábeis, mas apresenta uma incompletude¹⁰⁵. Trata-se, assim, de uma hipótese de “lacuna” na Lei nº 12.973/2014, por se tratar de uma situação que, segundo a intenção reguladora subjacente, precisaria

103. YAMASHITA, Douglas. *Direito Tributário – Uma Visão Sistemática*. São Paulo: Atlas, 2014, p. 345.

104. LARENZ, Karl. *Metodologia da Ciência do Direito*. 6ª Edição. Tradução de José Lamengo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. 570.

105. Como ensina Karl Larenz: “O termo ‘lacuna’ faz referência a um carácter incompleto. Só se pode falar de ‘lacunas’ de uma lei quando esta aspira a uma regulação para um determinado setor que é, em certa medida, completa” (LARENZ, Karl. *Metodologia da Ciência do*

de normatização. Até porque, se fosse a intenção do legislador negar a dedução dessa mais-valia, ele poderia tê-lo feito expressamente, em vez de simplesmente deixar de regular o tema.

Em segundo lugar, o princípio da igualdade deve exigir a mesma solução para ambos os casos, sem que haja justificativa para o tratamento diferenciado. Segundo Tercio Sampaio Ferraz Junior, a analogia ocorre quando uma norma jurídica, estabelecida para determinada “*facti species*”, é aplicável a uma conduta para a qual não há norma jurídica, havendo entre ambos os supostos fáticos uma semelhança¹⁰⁶. Assim, a existência de semelhança entre os supostos fáticos é essencial para a colmatação da lacuna por meio da analogia, pois esse mecanismo de integração está fundado, justamente, no princípio geral de que deve ser atribuído igual tratamento jurídico a casos semelhantes¹⁰⁷⁻¹⁰⁸, não apenas por uma questão de justiça, mas também pelo dever de coerência ínsito ao Direito.

Adiante, Ferraz Junior aponta que a semelhança entre os casos deve ser demonstrada sob o ponto de vista dos efeitos jurídicos, sendo que as coincidências entre eles devem ser maiores e juridicamente mais significativas do que as diferenças¹⁰⁹. Norberto Bobbio acrescenta que tal semelhança deve ser juridicamente relevante, constituindo a razão suficiente da regra jurídica, comumente chamada de “*ratio legis*”, ou seja, a justificação subjacente que inspira determinada prescrição normativa¹¹⁰.

Ora, no caso em exame, há clara semelhança entre as duas situações, que abrangem hipóteses em que o bem ou direito que deu causa a mais-valia não é transferido para o patrimônio da pessoa jurídica adquirente. A diferença é que o artigo 20, § 1º, da Lei nº 12.973/2014 trata apenas da hipótese de cisão parcial, quando, na verdade, o seu âmbito de aplicação deveria abranger qualquer evento societário.

Direito. 6ª Edição. Tradução de José Lamengo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. 526).

106. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. *Introdução ao Estudo do Direito – Técnica, Decisão, Dominação*. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 264.
107. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. *Introdução ao Estudo do Direito – Técnica, Decisão, Dominação*. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 265.
108. Como ensina Francesco Ferrara: “Perante casos de que o legislador não cogitou, o intérprete busca regulá-los no sentido em que o legislador os teria decidido se neles tivesse pensado. (...) O procedimento por analogia radica no conceito de que os factos de igual natureza devem ter igual regulamentação, e se um de tais factos encontra já no sistema a sua disciplina, esta forma o tipo do qual se deve inferir a disciplina jurídica geral que há de governar os casos afins” (FERRARA, Francesco. *Interpretação e Aplicação das Leis*. Tradução de Manuel A. Domingues de Andrade. 3ª Edição. Coimbra; Arménio Amado, 1978, p. 158).
109. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. *Introdução ao Estudo do Direito – Técnica, Decisão, Dominação*. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 265.
110. BOBBIO, Norberto. *Saggi sulla scienza giuridica*. Torino: G. Giappichelli Editore, 2011, pp. 50-51.

Ademais, não há justificativa para tratar as duas questões de forma diferente, pois em ambos os casos a pessoa jurídica adquirente suportou o custo de aquisição de um investimento avaliado pelo MEP, que deve ser dedutível para fins fiscais no momento do evento societário de incorporação, fusão ou cisão. Assim, considerando que a lei admitiu a dedução da mais valia em quotas fixas mensais, no prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da data do evento societário, é certo que o mesmo critério deve ser aplicado aos demais casos em que o bem ou direito que deu causa a mais-valia não é transferido para o patrimônio da pessoa jurídica adquirente, sob pena de violação ao conceito de renda e aos princípios da capacidade contributiva e da renda líquida.

Em terceiro lugar, a colmatação de lacunas deve observar os limites à atividade integradora do direito positivo. Como exemplo, há lacunas que apenas o legislador pode preencher, mediante a edição de lei, como ocorre no direito penal para a tipificação dos crimes¹¹¹ (“*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*”) e no direito tributário para a definição das hipóteses de incidência dos tributos (“*nullum tributum sine lege*”)¹¹²⁻¹¹³. Um limite claro à integração no direito tributário pode ser encontrado no próprio artigo 108, § 1º, do CTN, citado anteriormente, segundo o qual “o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.”

Como já mencionado acima, a situação ora examinada não está coberta pela vedação prevista no artigo 108, § 1º, do CTN, pois não se trata aqui de emprego de analogia para a exigência de tributo. O objetivo é simplesmente determinar o critério temporal de apropriação de um custo dedutível para fins fiscais.

A despeito da solução preconizada supra, é oportuno lembrar que a integração não gera um efeito generalizante, de modo que o preenchimento da lacuna ocorre sempre no caso concreto, devendo-se repetir o processo de argumentação em casos semelhantes¹¹⁴. Sendo assim, é recomendável que o legislador edite uma lei para resolver definitivamente a lacuna ora examinada, conferindo, assim, maior segurança jurídica para os contribuintes e evitando os litígios que certamente surgirão em razão do artigo 186, § 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

111. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. *Introdução ao Estudo do Direito – Técnica, Decisão, Dominação*. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 263.

112. PECZENIK, Aleksander. *On Law and Reason*. Netherlands: Springer, 2008, pp. 325-326.

113. Como adverte Hugo de Brito Machado: “(...) a lei que define as hipóteses de incidência tributária, não admite integração analógica. Não se poderia cogitar de lacuna porque em face do princípio da legalidade tributária, colocado no altiplano constitucional, não há tributo sem lei anterior que o institua” (MACHADO, Hugo de Brito. *Comentários ao Código Tributário Nacional*. Volume II. São Paulo: Atlas, 2004, p. 225).

114. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. *Introdução ao Estudo do Direito – Técnica, Decisão, Dominação*. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 268.

Outra forma de solucionar o problema, sem recorrer à analogia, seria a supressão do critério incompatível com o conceito de renda e com o princípio da capacidade contributiva.

De fato, o problema do § 1º do artigo 20 da Lei nº 12.973/2014 está justamente na expressão “na hipótese de cisão” (parcial), que pode ser excluída do texto legal sem violação da tese do legislador negativo, segundo a qual o Poder Judiciário pode declarar a nulidade total ou parcial de uma norma jurídica, afastando o critério de diferenciação indevidamente utilizado pelo legislador, mas sem instituir a norma jurídica considerada adequada, sob pena de exercer uma função legislativa e violar o princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal¹¹⁵.

Não é este o espaço para uma análise crítica da tese do legislador negativo¹¹⁶, cabendo apenas ressaltar que o princípio da separação dos poderes não pode servir de justificativa para amesquinhar a função do Poder Judiciário de controlar a compatibilidade de atos do Poder Legislativo com a Constituição Federal¹¹⁷.

Ademais, a integração do direito por analogia é expressamente admitida pelo artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“LINDB”)¹¹⁸ e pelo artigo 108, I, do CTN, motivo pelo qual não se pode confundi-la com o ativismo judicial¹¹⁹.

De todo modo, a verdade é que é possível evitar o problema concreto ora examinado mediante supressão da expressão “na hipótese de cisão” do § 1º do artigo 20 da Lei nº 12.973/2014, a fim de que qualquer bem ou direito não transferido para o patrimônio da pessoa jurídica sucessora, por ter sido alienado ou baixado antes do evento societário, seja deduzido do lucro real e da base de cálculo da CSLL em quotas fixas mensais e no prazo mínimo de 5 anos contados da data do evento societário.

Diante disso, conclui-se que o artigo 186, § 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 é ilegal, pois não se pode admitir que a Administração Tributária, por meio de ato normativo infralegal, restrinja o direito à dedução de uma parcela

115. “Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

116. Para uma análise crítica do tema, vide: ÁVILA, Humberto. *Sistema Constitucional Tributário*. 5ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 415-431.

117. ÁVILA, Humberto. *Sistema Constitucional Tributário*. 5ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 422.

118. Veja-se: “Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

119. Sobre ativismo judicial, conferir: RAMOS, Elival da Silva. *Ativismo Judicial – Parâmetros Dogmáticos*. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2015; TASSINARI, Clarissa. *Jurisdição e Ativismo Judicial: Limites da Atuação do Judiciário*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.

do custo de aquisição legitimamente suportado pelo contribuinte. Em rigor, na ausência de regra específica, essa mais-valia deveria ser considerada dedutível no momento da operação societária, que constitui o evento crítico de realização. Porém, de forma conservadora, seria possível aplicar, por analogia, o artigo 20, § 1º, da Lei nº 12.973/2014, hipótese em que a mais-valia poderá ser deduzida do lucro real e da base de cálculo da CSLL em quotas fixas mensais e no prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da data do evento societário. Outra opção, que conduz ao mesmo resultado, seria suprimir a expressão “na hipótese de cisão” do § 1º do artigo 20 da Lei nº 12.973/2014, evitando-se, assim, qualquer discussão relativa à tese do legislador negativo e à violação da separação dos poderes.

Por fim, vale ressaltar que a mesma interpretação pode ser aplicada, com as devidas adaptações, para a menos-valia de ativos não transferidos para a pessoa jurídica adquirente no momento da combinação de negócios. Tecnicamente, a menos-valia de ativos pode ser considerada realizada no momento do evento societário, mas é possível aplicar por analogia, ou por nulidade parcial de texto, com supressão da expressão “na hipótese de cisão”, o regime do § 1º do artigo 21 da Lei nº 12.973/2014, a fim de que o valor da menos-valia seja oferecido à tributação pelo IRPJ e pela CSLL em quotas fixas mensais no prazo máximo de 5 (cinco) anos.

2.14. A mais ou menos-valia de passivos assumidos

Outra deficiência na redação do artigo 20 da Lei nº 12.973/2014 diz respeito à omissão da mais-valia dos passivos assumidos na combinação de negócios. Esse dispositivo legal faz alusão apenas à mais-valia de bens ou direitos, ao determinar que o valor da mais-valia deverá ser incorporado ao seu custo de aquisição. Veja-se:

“Art. 20. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo existente na contabilidade, na data da aquisição da participação societária, referente à mais-valia de que trata o inciso II do *caput* do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, decorrente da aquisição de participação societária entre partes não dependentes, *poderá ser considerado como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu causa*, para efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do cômputo da depreciação, amortização ou exaustão. (...)” (g.n.)

Da mesma forma, o artigo 21 da Lei nº 12.973/2014 também deixou de tratar da menos-valia referente aos passivos assumidos na combinação de negócios. Veja-se:

“Art. 21. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo existente na contabilidade, na data da aquisição da participação societária, referente à menos-valia de que trata o inciso II do *caput* do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de

26 de dezembro de 1977, deverá ser considerado como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu causa para efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do cômputo da depreciação, amortização ou exaustão.”

Ocorre que os preceitos normativos supra entram em aparente contradição com o disposto no artigo 20, § 5º, do Decreto-lei nº 1.568/1977, segundo o qual a aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo MEP exige o reconhecimento e a mensuração: (i) dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo; e (ii) do ágio por rentabilidade futura ou do ganho proveniente de compra vantajosa. Confira-se a redação do texto legal:

“§ 5º. A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio líquido exige o reconhecimento e a mensuração:

I – primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo; e

II – posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (*goodwill*) ou do ganho proveniente de compra vantajosa.”

Como se vê, o artigo 20, § 5º, do Decreto-lei nº 1.568/1977 menciona expressamente a mensuração a valor justo dos passivos assumidos, em linha com o Pronunciamento Técnico CPC nº 15, segundo o qual o adquirente deve reconhecer, na data da operação de combinação de negócios, os “ativos identificáveis e passivos assumidos” da adquirida pelos seus respectivos valores justos (item 20).

Essa regra é corroborada pelo artigo 178, § 7º, inciso VI, da Instrução Normativa RFB nº 1700/2017, o qual lista, entre outras informações que devem constar do sumário do laudo de avaliação a ser protocolado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, a “relação individualizada dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos com os respectivos valores contábeis e valores justos”.

O exemplo clássico é de uma contingência não reconhecida pela sociedade adquirida, que reduz o valor do seu acervo líquido e, por consequência, aumenta o valor do ágio ou diminui o valor do ganho por compra vantajosa. O item 13 do Pronunciamento Técnico CPC nº 15 dispõe que, na aplicação do método de aquisição, podem ser identificados ativos e passivos que não tenham sido anteriormente reconhecidos nas demonstrações contábeis da sociedade adquirida.

Adiante, o item 23 do Pronunciamento Técnico CPC nº 15 estabelece que, exclusivamente para fins de aplicação do “método de aquisição” no contexto de uma operação de combinação de negócios, não se aplicam os critérios de reconhecimento de passivos previstos no Pronunciamento Técnico CPC nº 25.

Por isso, o Pronunciamento Técnico CPC nº 15 determina que, na data de aquisição, deve ser reconhecido um “passivo contingente assumido em combinação de negócios se ele for uma obrigação presente que surge de eventos passados

e se seu valor justo puder ser mensurado com confiabilidade”, ainda que não seja provável que o passivo contingente resulte em saída de recursos para a liquidação da obrigação (item 23).

Assim, a pessoa jurídica adquirente deve reconhecer pelo valor justo, na data da aquisição, eventual passivo contingente assumido na operação de combinação de negócios, mesmo que não seja provável a saída de recursos para a liquidação da obrigação e que o valor em questão não esteja provisionado pela sociedade adquirente¹²⁰. Na prática, isso significa que a pessoa jurídica adquirente deve reconhecer o passivo contingente assumido, independentemente dos critérios do Pronunciamento Técnico CPC nº 25. Como exemplo, um passivo contingente com chance de perda possível, que apenas exige a divulgação em notas explicativas sob o enfoque do Pronunciamento Técnico CPC nº 25, pode vir a ser reconhecido como um passivo contingente assumido pela sociedade adquirente, por ocasião da aplicação do “método da aquisição”.

Segundo o item 20 da Interpretação Técnica ICPC nº 09, o método de aquisição do Pronunciamento Técnico CPC nº 15 pode fazer com que sejam reconhecidos ativos e passivos que não estavam registrados nas demonstrações contábeis da adquirida, devendo ser controlados extracontabilmente para fins de aplicação do MEP e reconhecidos contabilmente nas demonstrações financeiras consolidadas. A alínea “b” do item 20 dessa Interpretação Técnica trata do reconhecimento de passivos contingentes não contabilizados pela sociedade adquirida nos seguintes termos:

“20 (...) (b) haja a inclusão de passivos contingentes também não reconhecidos na investida (como certas contingências fiscais, cíveis, etc.), mas que tenham sido objeto de atribuição de valor por parte do investidor para assumi-las na aquisição, ou seja, tenham influenciado o valor pago na aquisição desses instrumentos patrimoniais; conseqüentemente, eventual passivo contingente não sujeito ao reconhecimento contábil nas demonstrações da investida por força do Pronunciamento Técnico CPC 25, mas que tenha provocado redução do valor pago ou a pagar por parte da adquirente, será extracontabilmente reconhecido para fins da determinação do patrimônio líquido da investida quando da aplicação da equivalência patrimonial e será reconhecido para fins de consolidação de demonstrações contábeis. Afinal, nessa situação esse passivo contingente terá provocado efeito no caixa da adquirente por haver reduzido o valor da aquisição.”

Daí se nota que há uma diferença entre a legislação tributária e o Pronunciamento Técnico CPC nº 25 em relação ao ponto de partida para o desdobramento do custo de aquisição do investimento.

120. ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti; ALMEIDA, Rafael Jachelli. *Regulamentação Fiscal das Normas Contábeis do IFRS e CPC: Lei nº 12.973/14*. São Paulo: Atlas, 2015, p. 142.

O artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 determina que o contribuinte que avaliar investimento com base no MEP deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição tomando como ponto de partida o valor de patrimônio líquido na época da aquisição. Veja-se:

“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:

I – *valor de patrimônio líquido na época da aquisição*, determinado de acordo com o disposto no artigo 21 (...). (g.n.)

Por outro lado, pelas regras contábeis do Pronunciamento Técnico CPC nº 15, há a necessidade de realização de ajustes nas demonstrações contábeis da sociedade adquirida, com base no “método da aquisição”. Um exemplo de ajuste é justamente o caso de uma contingência não reconhecida pela sociedade adquirida.

A primeira questão que surge na análise do tema consiste em saber se o artigo 20, § 5º, I, do Decreto-lei nº 1.568/1977, ao tratar dos “passivos assumidos”, abrangeu os passivos contingentes que não estavam registrados na escrituração contábil da pessoa jurídica adquirida. Em rigor, a expressão “passivos assumidos” deve ser interpretada de forma ampla, a fim de que os passivos contingentes não registrados contabilmente também sejam levados em consideração na alocação do preço.

A segunda questão diz respeito à forma de reconhecimento dos passivos contingentes assumidos. Na ausência de uma regra específica sobre a mais ou menos valia de passivo na Lei nº 12.973/2014, seria razoável entender que o aumento ou a redução do patrimônio líquido da sociedade investida, no âmbito do “método da aquisição” da combinação de negócios, deve produzir efeitos fiscais reflexos na apuração da mais ou menos-valia de ativos líquidos e do ágio ou ganho por compra vantajosa.

Para tanto, deve-se utilizar a regra prevista no artigo 21, inciso II, do Decreto-lei nº 1.598/1977, alterado pela Lei nº 12.973/2014, segundo o qual a pessoa jurídica adquirente poderá fazer ajustes no balanço patrimonial da sociedade investida para eliminar as diferenças relevantes decorrentes da diversidade de critérios contábeis.

Com isso, a mais ou menos-valia de passivo reduziria ou aumentaria o valor do patrimônio líquido da sociedade investida para efeito de aplicação do “método da aquisição” e, conseqüentemente, alteraria o valor da mais ou menos-valia de ativos líquidos a valor justo e do ágio ou ganho por compra vantajosa, de modo que a omissão da Lei nº 12.973/2014 passaria a ser contornada no âmbito da interpretação.

Após o evento de fusão, incorporação ou cisão, as consequências fiscais da mais ou menos-valia de passivo deverão estar em conformidade com os impactos provocados na apuração do custo de aquisição da participação societária.

Como exemplo, a mais-valia de passivo aumenta o valor do patrimônio líquido da sociedade investida e diminui o valor do ágio. Consequentemente, após o evento societário, a mais-valia do passivo deverá ser controlada em subconta vinculada à obrigação original, sendo que o respectivo montante deve ser considerado dedutível do lucro real e da base de cálculo de CSLL no momento do efetivo adimplemento da obrigação, observado o limite do custo efetivamente suportado pela pessoa jurídica.

Diversamente, a menos-valia do passivo diminui o valor do patrimônio líquido da sociedade investida e aumenta o valor do ágio. Por conseguinte, a menos-valia de passivo, tal como ocorre no exemplo da contingência não reconhecida pela sociedade adquirida, não poderia ser deduzida do lucro real e da base de cálculo da CSLL, em virtude do aumento do valor do ágio ou da mais-valia de ativos para fins fiscais.

Observe-se que tal interpretação está amparada na ideia de simetria e paridade, tendo em vista que o registro da mais ou menos-valia de ativos e passivos decorre da decomposição do custo de aquisição de um investimento avaliado pelo MEP e as regras tributárias que disciplinam o tema prescrevem critérios para a alocação temporal do resultado apurado pela pessoa jurídica adquirente no evento societário.

Assim, tanto a mais ou menos-valia de ativos (bens e direitos), quanto a mais ou menos-valia de passivos (obrigações) resultam da decomposição obrigatória do custo de aquisição do investimento e afetam, para mais ou para menos, o cálculo do *goodwill* e do ganho por compra vantajosa nas operações de combinação de negócios, o que deve guiar o tratamento dos valores em questão, em linha com o conceito de renda, com o princípio da renda líquida e com a ideia de paridade de tratamento entre os fatores que provocam as mutações patrimoniais, como exige o princípio da universalidade.

2.15. O ganho por compra vantajosa

O item 34 do Pronunciamento Técnico CPC nº 15 dispõe que o ganho por compra vantajosa ocorrerá quando, na operação de combinação de negócios, o valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos for maior do que a contraprestação transferida pelo adquirente. Nesta hipótese, o adquirente deve reconhecer o ganho por compra vantajosa, auferido na data da aquisição, na demonstração de resultado do exercício elaborada para fins contábeis¹²¹.

121. Veja-se: “Ocasionalmente, um adquirente pode realizar uma compra vantajosa, assim entendida como sendo uma combinação de negócios cujo valor determinado pelo item 32(b) é maior que a soma dos valores especificados no item 32(a). Caso esse excesso de valor permaneça após a aplicação das exigências contidas no item 36, o adquirente deve

Sabe-se que, como regra geral, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo e passivo, em decorrência de sua avaliação a valor justo¹²², são registradas na conta de ajuste de avaliação patrimonial (“AAP”), que integra o patrimônio líquido. A conta de AAP, instituída pela Lei nº 11.638/2007, serve justamente para evitar o trânsito por conta de resultado de valores ainda não realizados¹²³. Porém, em circunstâncias específicas, as regras contábeis determinam o registro da contrapartida da avaliação de ativos a valor justo diretamente no resultado do exercício, como ocorre com os ativos biológicos, com as propriedades para investimento¹²⁴ e, em determinados casos, com os instrumentos financeiros.

Isso também ocorre com o ganho por compra vantajosa, que é reconhecido diretamente como resultado do exercício da sociedade adquirente para fins contábeis. Ou seja, diferentemente do que ocorre em outras hipóteses de avaliação de ativos a valor justo, o ganho por compra vantajosa não é registrado na conta de AAP no patrimônio líquido.

Em suma, pode-se assentar que, para fins contábeis, o ganho por compra vantajosa ocorrerá quando o valor justo dos ativos líquidos adquiridos superar o custo de aquisição pago ou suportado pelo adquirente, sendo que a sua contrapartida deverá ser registrada diretamente na demonstração do resultado do exercício.

O artigo 23 da Lei nº 12.973/2014 disciplinou o tratamento do ganho por compra vantajosa nas operações de incorporação, fusão ou cisão. Segundo esse preceito normativo, o ganho por compra vantajosa somente será computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL no momento da alienação ou baixa, salvo se houver incorporação, fusão ou cisão entre a pessoa jurídica investidora e a investida, caso em que, a partir do evento societário, desencadeia-se a tributação do ganho por compra vantajosa em parcelas mínimas mensais equivalentes a 1/60. Assim, após o evento societário, o ganho por compra vantajosa será computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL no prazo máximo de 5 (cinco) anos¹²⁵.

reconhecer o ganho resultante, na demonstração de resultado do exercício, na data da aquisição. O ganho deve ser atribuído ao adquirente”.

122. Artigo 182, § 3º, da Lei nº 6.404/1976.

123. Segundo Edison Carlos Fernandes: “(...) a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado dos ativos e passivos (...) ao ser registrada em conta do patrimônio líquido, estará postergando o seu reconhecimento no resultado, como ganho ou perda, conforme o caso, para obedecer ao regime de competência” (FERNANDES, Edison Carlos. *Impacto da Lei nº 11.638/07 sobre os Tributos e a Contabilidade*. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 73).

124. MUNIZ, Ian; MONTEIRO, Marco. *Tributos Federais e o Novo Padrão Contábil – Comentários à Lei nº 12.973/14*. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 93.

125. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. “Depurações do Lucro Contábil para Determinação do Lucro Tributável”. In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 5º Volume. São Paulo: Dialética, 2014, p. 365.

A compatibilidade do artigo 23 da Lei nº 12.973/2014 com o sistema tributário brasileiro é questionada com veemência por Ricardo Mariz de Oliveira, para quem o ganho por compra vantajosa, que decorre da diferença entre o preço de aquisição (contraprestação) e o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, está sujeito a incertezas e inseguranças inaceitáveis para a quantificação das obrigações tributárias, que estão submetidas ao princípio da legalidade e a outras limitações ao poder de tributar¹²⁶.

Realmente, considerando que o ganho por compra vantajosa decorre da avaliação a valor justo dos ativos líquidos identificados na participação societária adquirida, é de se questionar a possibilidade de incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores cercados de incertezas, que poderão oscilar de acordo com as tendências econômico-financeiras e mercadológicas, sobretudo, no caso de mercados inativos, ilíquidos ou desordenados. Em rigor, o valor justo representa mera variação nominal de um item registrado na contabilidade, que pode, inclusive, desaparecer em momentos posteriores, em caso de desvalorização. Por isso, a neutralização dos impactos tributários decorrentes da avaliação de ativos e passivos com base no valor justo não representa uma regalia concedida pelo legislador em favor dos contribuintes, mas, sim, uma exigência necessária para a observância de diretrizes fundamentais que conformam o Sistema Tributário Nacional, como o princípio da legalidade e o princípio da capacidade contributiva¹²⁷.

Para Heron Charneski, o artigo 23 da Lei nº 12.973/2014, ao prever a tributação do ganho por compra vantajosa no prazo máximo de 5 (cinco) anos, é incompatível com o artigo 43 do CTN, pois as operações de incorporação, fusão ou cisão configuram uma situação de continuidade (sucessão a título universal), que não geram mudança da posição patrimonial do contribuinte e equivalem a mera troca de ativos. Assim, o ganho por compra vantajosa não poderia ser submetido à incidência de IRPJ e CSLL, ainda que de forma fracionada, à razão de 1/60 (um sessenta avos) por mês¹²⁸.

126. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. "Regime Tributário da Compra Vantajosa – Questões Fundamentais". In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 4º Volume. São Paulo: Dialética, 2013, pp. 251-268; OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. "Depurações do Lucro Contábil para Determinação do Lucro Tributável". In: *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*. 5º Volume. São Paulo: Dialética, 2014, p. 365.

127. SANTOS, Ramon Tomazela. "A não incidência de PIS e COFINS sobre o ganho por compra vantajosa apurado na aquisição de ativos imobilizados em operação de combinação de negócios". *Revista Fórum de Direito Tributário*, nº 85. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 127.

128. CHARNESKI, Heron. *Normas Internacionais de Contabilidade e Direito Tributário Brasileiro*. Série Doutrina Tributária. Volume XXIV. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 213.

2.16. Extensão de efeitos para a CSLL

O artigo 50 da Lei nº 12.973/2014 estendeu a aplicação das regras jurídicas examinadas supra para fins de determinação da base de cálculo da CSLL, por meio de norma jurídica de remissão interna¹²⁹. Assim, embora as bases de cálculo do IR-PJ e da CSLL não sejam idênticas, não há diferenças em relação ao tema ora examinado.

2.17. Conclusões

Diante de todas as considerações supra, é possível concluir que:

(i) após a edição da Lei nº 12.973/2014, a mensuração e a alocação do ágio por rentabilidade futura passaram a seguir a sistemática do Pronunciamento Técnico CPC nº 15, por meio do qual a sociedade investidora deve realizar a alocação do preço de aquisição ao valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos, sendo que apenas o valor residual poderá ser tratado como ágio por rentabilidade futura;

(ii) o ágio decorrente de uma combinação de negócios, que não tomou a forma de aquisição de participação societária, não se submete ao regime tributário do artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 e do artigo 22 da Lei nº 12.973/2014;

(iii) no caso da chamada “aquisição reversa”, para fins tributários, o custo de aquisição deve ser desdobrado pela pessoa jurídica que detém a titularidade jurídica da participação societária, sendo irrelevante o tratamento conferido pela contabilidade à operação para fins de determinação do “adquirente contábil”;

(iv) a referência feita pelo artigo 20 do Decreto-lei nº 1.598/1977 à data de aquisição da participação societária deve ser compreendida no contexto da avaliação do investimento pelo MEV, o que pressupõe a caracterização do controle societário ou a verificação da influência significativa;

(v) a Lei nº 12.973/2014 não estabeleceu parâmetros específicos para a mensuração do valor justo dos ativos e passivos assumidos na combinação de negócios, o que remete o intérprete à disciplina contábil, por meio de um processo de abertura cognitiva;

(vi) em uma combinação de negócios, a pessoa jurídica adquirente deve reconhecer quaisquer ativos ou passivos fiscais diferidos como ativos e passivos identificáveis na data da aquisição, de modo que esses valores podem afetar o valor do ágio de rentabilidade futura ou do ganho por compra vantajosa, que apresentam caráter residual no regime da Lei nº 12.973/2014;

129. Veja-se: “Aplicam-se à apuração da base de cálculo da CSLL as disposições contidas nos arts. 2º a 8º, 10 a 42 e 44 a 49”.

(vii) normalmente, o ágio por expectativa de rentabilidade futura não tem prazo de vida útil e, por isso, não pode ser objeto de amortização contábil, submetendo-se ao teste relativo ao valor recuperável de ativos (“*impairment*”);

(viii) eventual teste de recuperabilidade realizado após a aquisição do investimento, mas antes da incorporação, fusão ou cisão, não deverá ocasionar efeitos fiscais adversos para o contribuinte, uma vez que o valor do ágio a ser amortizado é aquele existente na escrituração contábil no momento da aquisição da participação societária;

(ix) nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo de mais-valia de ativos existente na contabilidade, na data da aquisição da participação societária, poderá ser considerado como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu causa, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital e do cômputo da depreciação, amortização ou exaustão;

(x) o artigo 186, § 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 é ilegal, pois não se pode admitir que a Administração Tributária, por meio de ato normativo infralegal, restrinja o direito à dedução de uma parcela de um custo de aquisição legitimamente suportado pelo contribuinte;

(xi) em rigor, na ausência de regra específica, essa mais-valia deveria ser considerada dedutível no momento da operação societária, que constitui o evento crítico de realização. Porém, de forma conservadora, seria possível aplicar, por analogia, o artigo 20, § 1º, da Lei nº 12.973/2014, hipótese em que a mais-valia poderá ser deduzida do lucro real e da base de cálculo da CSLL em quotas fixas mensais e no prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da data do evento societário;

(xii) alternativamente, seria possível suprimir a expressão “na hipótese de cisão” do § 1º do artigo 20 da Lei nº 12.973/2014, evitando-se, assim, qualquer discussão relativa à tese do legislador negativo e à violação da separação dos poderes;

(xiii) a mais ou menos-valia de passivo deve reduzir ou aumentar o valor do patrimônio líquido da sociedade investida para efeito de aplicação do “método da aquisição” e, conseqüentemente, alterar o valor da mais ou menos-valia de ativos líquidos a valor justo e do ágio ou ganho por compra vantajosa;

(xiv) segundo o artigo 23 da Lei nº 12.973/2014, o ganho por compra vantajosa será computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL no prazo de no máximo 5 (cinco) anos.

Para encerrar, é oportuno apresentar, na tabela a seguir, as principais diferenças entre a disciplina contábil e o regime tributário do ágio de rentabilidade futura, que foram exploradas pormenorizadamente nos tópicos anteriores.

Diferenças	Regime Contábil	Tratamento tributário antes da Lei nº 12.973/2014	Tratamento tributário após a Lei nº 12.973/2014
Reconhecimento	Operação de Combinação de Negócios (aquisição de controle)	Investimento avaliado pelo MEP	Investimento avaliado pelo MEP, desde que as partes sejam independentes
Mensuração	Diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor justo dos ativos líquidos da sociedade	Diferença entre o custo de aquisição e o valor do patrimônio líquido contábil	Diferença entre o custo de aquisição e o valor justo dos ativos líquidos da sociedade
Alocação	- valor patrimonial - mais ou menos-valia de ativos e passivos - <i>goodwill</i>	- valor patrimonial - valor de mercado de bens do ativo - rentabilidade futura - intangíveis	- valor patrimonial - mais ou menos-valia de ativos e passivos - <i>goodwill</i>
Aproveitamento do ágio de rentabilidade futura	Teste de recuperabilidade (<i>impairment</i>)	Amortização linear do ágio à razão de 1/60 por mês	Dedução linear do ágio à razão de 1/60 por mês

Fonte: Elaborada pelo autor.